

ciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo *razonable* o ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio.

Art. 8º. Garantías judiciales

1º) Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo *razonable*, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.

Art. 32. Correlación entre Deberes y Derechos:

2º) Los Derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común en una sociedad democrática.

e.3) Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

Art. 9º.

Inc. 1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión *arbitrarias*. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta.

3. Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo *razonable* o a ser puesta en libertad. La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier otro momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo.

e.4) Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

Art. 10. Los Estados partes en el presente Pacto reconocen que:

2. Se debe conceder especial protección a las madres durante un período de tiempo *razonable* antes y después del parto. Durante dicho período a las madres que trabajen se les debe conceder licencia con remuneración o con prestaciones adecuadas de seguridad social.

Art. 14. Todo Estado parte en el presente Pacto que, en el momento de hacerse parte en él, aún no haya podido instituir en su territorio metropolitano o en otros territorios sometidos a su jurisdicción la obligatoriedad y la gratuidad de la enseñanza primaria, se compromete a elaborar y adoptar,

dentro de un plazo de dos años, un plan detallado de acción para la aplicación progresiva, dentro de un número *razonable* de años fijado en el plan, del principio de la enseñanza obligatoria y gratuita para todos.

f) Ingerencia de los tratados internacionales

Si bien, como ya dijimos, toda restricción —solo por ley formal— y toda regulación normativa deben ser razonables sin distinción alguna entre los diferentes derechos constitucionales, los tratados internacionales han querido reforzar algunos de ellos para que su regulación sea aún más medida y controlada con un filtro riguroso del test de razonabilidad.

Los derechos protegidos son: 1) Vida privada, familia, domicilio, correspondencia, honra y reputación (art. 12 de la DUDH); 2) Nacionalidad (art. 15.2 de la DUDH); 3) Propiedad (art. 17 de la DUDH); 4) detención o privación de libertad (art. 24.3 de la DUDH y art. 9º del PIDCyP); 5) Duración del trabajo (art. 24.5. de la DUDH); 6) Juzgamiento de una persona detenida (art. 7º de la CADH y art. 9º del PIDCyP); 7) Garantía judicial (art. 8º de la CADH); 8) Limitación de los derechos por las justas exigencias del bien común en una sociedad democrática (art. 32.2 de la CADH); 9) Protección de la madre antes y después del parto (art. 10 del PIDESyC) y; 10) Enseñanza obligatoria y gratuita en todos los Estados miembros (art. 14 del PIDESyC).

Si bien todos estos derechos no son absolutos, sino regulables, estas regulaciones tendrán un muy riguroso test de razonabilidad, y en muchos casos estándares fijos inmodificables para los Estados miembros, que surgirán de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las opiniones de la Comisión de Derechos Humanos y las observaciones del Comité de Derechos Humanos.

El Comité de Derechos Humanos (ONU) en su Observación General N° 16 del 08 de abril de 1988, mantuvo que el cumplimiento del art. 17 del PIDCP exige que la integridad y el carácter confidencial de la correspondencia estén protegidos *de iure* y *de facto*. La correspondencia debe ser entregada al destinatario sin ser intervenida ni abierta o leída de otro modo. Debe prohibirse la vigilancia, por medios electrónicos o de otra índole, la intervención de las comunicaciones telefónicas, telegráficas o de otro tipo, así como la intervención y grabación de conversaciones. Los registros en el domicilio de una persona deben limitarse a la búsqueda de pruebas necesarias y no debe permitirse que constituyan un hostigamiento (párrafo 8).

La Corte Interamericana de Derechos Humanos en su Opinión Consultiva N° 6/86 del 09 de mayo de 1986, en ocasión de glosar los alcances del art. 32 de la CADH, ha dicho que el requisito según el cual las leyes ha de ser dictadas por razones de interés general significa que deben haber sido adoptadas en función del "bien común", concepto que ha de interpretarse como elemento integrante del orden público del Estado democrático. "Bien común" y "orden público" en la CADH —afirma la CIDH— son términos que deben interpretarse dentro del sistema de la misma, que tiene una concepción propia según la

cual los Estados Americanos "requieren la organización política de los mismos sobre la base del ejercicio efectivo de la democracia representativa" (art. 3.d de la Carta de la OEA); y los derechos del hombre, que tiene como fundamento los atributos de la persona humana, deben ser objeto de protección internacional (considerandos párrafo 2 DADDH; Preámbulo, párrafo 2 de la CADH).

El Comité de Derechos Humanos ha dicho que no resulta razonable si una persona es llevada ante el juez luego de 10 semanas de detención, ser mantenido en prisión por lo menos 9 días antes de comunicarle los motivos de su detención y tener una demora de 3 semanas antes de ser llevado ante el juez competente.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso: "Suárez Rosero" del 12 de noviembre de 1997, deja sentado que la sola constatación de que la víctima fue privada durante 36 días de toda comunicación con el mundo exterior y particularmente con su familia, le permite a la CIDH concluir que el denunciante fue sometido a tratos crueles, inhumanos y degradantes, más aún cuando ha quedado demostrado que esta incomunicación fue arbitraria y realizada en contravención de la normativa interna del Estado denunciado.

Más recientemente, la CIDH manifestó, en cuanto a las condiciones de reclusión, que el hecho de que la víctima fue mantenida durante un año bajo aislamiento riguroso, hacinada con otros presos en una celda pequeña, sin ventilación ni luz natural, que las visitas que podía recibir estaban sumamente restringidas, que la atención médica brindada a la víctima era muy deficiente y que 20 días después de haber sido privado de su libertad, cuando no había sido procesado, y mucho menos condenado, el detenido fue exhibido ante los medios de comunicación, vestido con ropa infamante, junto a otros detenidos, como autor del delito de traición a la patria, constituyen una violación al artículo 5.1 y 2 de la CADH.

g) Recapitulación del principio de razonabilidad

Si bien el principio de razonabilidad es un principio ampliamente utilizado podemos notar que no se encuentra en nuestra constitución en forma explícita, sino en forma implícita a través del art. 28 y 33 de la Constitución Nacional, en conjunción con el art. 16, 17 y el preámbulo.

Pero si consideramos que todo lo arbitrario es irrazonable, y a su vez es inconstitucional, tenemos más elementos explícitos de este principio, para poder elaborar un test de razonabilidad en las formas y métodos que los autores calificados de la doctrina han desarrollado.

Por su parte, la reforma constitucional al dar expreso tratamiento a la acción de amparo le ha otorgado la herramienta procesal fundamental al principio de razonabilidad, en los casos en que una autoridad pública altera un derecho con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta derechos y garantías reconocidos en la Constitución Nacional, un tratado o una ley.

Sin embargo, fueron los tratados internacionales con jerarquía constitucional los que en mayor medida han ayudado a enriquecer los elementos del principio de razonabilidad, otorgando a las decisiones del estado reglas claras sobre ciertos derechos sensibles, que expresamente deben respetarse para no transformar dicha decisión en arbitrarias o irrazonables. De esta forma se quita el libre albedrío de las autoridades públicas para fijar estándares claros y permanentes, según la naturaleza del derecho, limitando actitudes caprichosas y carentes de argumentos.

Como decía Montesquieu, "...constituye un triunfo de la libertad que las leyes criminales establezcan cada pena conforme a la naturaleza específica del delito. Toda arbitrariedad se acaba; la pena no surge del albedrío del legislador, sino de la naturaleza de las cosas y no es ya el hombre quien hace violencia al hombre...".

CAPITULO VI

LAS CLÁUSULAS DE BIENESTAR GENERAL

SUMARIO: 1. Introducción. — 2. Cláusula del bienestar general. — 3. Cláusulas del comercio. a) Antecedentes en el Derecho norteamericano. b) Regulación en el derecho nacional. — 4. Cláusulas del progreso o de prosperidad. a) Antecedentes históricos. b) Constitución histórica 1853-60. c) Reforma constitucional de 1994 y el fortalecimiento del constitucionalismo social. d) Tratados internacionales con jerarquía constitucional. — 5. Cláusulas del desarrollo humano. — 6. A modo de conclusión.

1. INTRODUCCIÓN

El Estado tiene como meta principal dar cumplimiento a los fines enunciados en el Preámbulo de la Constitución Nacional como ser: afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común y promover el bienestar general. Estos a su vez se encuentran complementados con los artículos 14, 14 bis, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 33, 75 incs. 13, 18 y 19, entre muchos otros.

Para la observancia de dichos fines necesita proveerse de ciertos medios, y cuanto mayor sean los fines mayor va a ser el despliegue de la actividad administrativa del Estado, implementando nuevas técnicas intervencionistas desconocidas o no generalizadas en el siglo XIX, provocando la invasión del Derecho Público en el campo privado.

Es por ello que la Argentina ha tenido una intervención irregular por parte del Estado. En una etapa inicial el Estado Liberal "abstencionista" realizaba su casi exclusivo cometido: el mantenimiento del orden público, mediante medidas de policía administrativa por medio de mandatos y prohibiciones. Ese aspecto autoritario de la intervención estatal se desvaneció cuando la Administración presta servicios públicos en forma generalizada.

A mediados del siglo XX el Estado no se limita a prestar servicios públicos sino que participa en toda la actividad económica, industrial y comercial. Luego en el siglo XX, comienza la era de las privatizaciones de los servicios públicos que pasan en su totalidad a manos privadas, reteniendo el Estado el control de los servicios a través de ente reguladores (1).

(1) Argentina fue uno de los pocos países del mundo que en su afán de modernizar su economía paso a manos privados no solamente los servicios públicos sino también los recursos naturales —petróleo, gas y agua— que son el patrimonio de nuestro país.

Ahora bien, uno de los fines más amplios y más significativos que tiene el Estado Federal es el bienestar general o bien común de todos los ciudadanos. Y para que ese fin pueda llevarse a cabo la Constitución Nacional le ha otorgado entre los diferentes medios o herramientas necesarias las "cláusulas del bienestar general" y sus diferentes especies como son las denominadas "cláusulas de comercio", "cláusulas del progreso" y "cláusulas del desarrollo humano".

2. CLÁUSULA DEL BIENESTAR GENERAL

Las cláusulas son pautas que se dan para cumplir un determinado convenio o contrato celebrado entre dos o más partes. Las cláusulas constitucionales han adoptado este criterio y las ha incorporado entre sus fines más preciados, donde el contrato es el contrato social—bajo el instrumento jurídico de la constitución—y las personas involucradas son los ciudadanos y el Estado, sea éste nacional o provincial.

Es por ello que nosotros consideramos que además de estar explicitadas en la segunda parte de la Constitución Nacional, al ser una atribución o un medio de los poderes del estado, deberían estar plasmadas, además, en la primera parte de la Constitución por ser los habitantes los destinatarios directos de los beneficios que por ella rijan y pudiendo de este modo acudir a la justicia para que las cláusulas sean instrumentadas y aplicadas.

La regulación de la cláusula del bienestar general la ostenta tanto la Nación como las Provincias, según lo dispuesto por el art. 75 inc. 18 y 19 y art. 125 de la Constitución Nacional. Además de los descriptos en los tratados internacionales con jerarquía constitucional: en el art. 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el art. 2º del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Ante esta concurrencia de facultades entre la Nación y las Provincias, sumadas a su obligatoriedad internacional, han transformado a esta cláusula en una de las que más debatidas y contenidos han logrado mayor claridad con la reforma constitucional.

3. CLÁUSULAS DEL COMERCIO

a) Antecedentes en el Derecho Norteamericano

Esta cláusula está tomada de la Constitución de los EE.UU., art. 1º, sección 8 cláusula 3 establece: "...El Congreso tendrá potestad... para regular el comercio con las naciones extranjeras, y entre los diversos Estados, y con las tribus indias..." Esta facultad fue sancionada cuando los trece Estados originales de los Estados Unidos ocupaban una superficie inferior a la cuarta parte del área ahora cubierta por sus actuales cincuenta estados. Resulta una de las potestades más importantes que tiene el Poder Legislativo federal dentro de sus funciones específicas.

La interpretación de la cláusula de comercio en los Estados Unidos se ha efectuado en tres dimensiones diferentes (2):

- Los límites y restricciones al poder de los Estados que surgen como consecuencia de la existencia de la cláusula de comercio en la Constitución y que han dado origen a la doctrina de la cláusula comercial negativa o durmiente.
- La extensión y alcance del poder del Congreso que da lugar a la doctrina de la cláusula de comercio positiva.
- Las relaciones entre las leyes federales y las leyes de los Estados con relación al comercio interjurisdiccional y la forma de interacción entre esos dos órdenes y que dan origen a la doctrinas de la sustitución y de la conjunción.

Siguiendo en lo fundamental el interesante desarrollo que de este tema realiza Borrajo Iniesta (3), distinguiremos, al solo efecto de su estudio, tres etapas históricas (4):

- La primera, que abarca desde la sanción y aprobación de la Constitución de los Estados Unidos hasta 1851.
- La segunda, que se extiende desde 1851 a 1937, y donde la cláusula de comercio tiene un relevante desarrollo en la jurisprudencia de la Suprema Corte.
- La tercera, que comprende los desarrollos posteriores a 1937 y que marca una significativa diferencia en la interpretación jurisprudencial.

En el caso "Gibbons v. Ogden" (5), de 1824, la Suprema Corte de los Estados Unidos, con el voto de su presidente Marshall, sostuvo una interpretación amplia del término "comercio" contenido en el art. I, Sección octava, cláusula tercera de la Constitución de los Estados Unidos; "comercio"—expresó—"es indudablemente tráfico, pero es algo más, es intercambio" (6).

(2) ZIULU, ADOLFO: "La cláusula comercial y su influencia en el Derecho Público provincial", JA, 2003-I-1108.

(3) BORRAJO INIESTA, IGNACIO, *Federalismo y unidad económica. La cláusula de comercio de la Constitución de los Estados Unidos*, 1986, Madrid, p. 43.

(4) ZIULU, ADOLFO, op. cit.

(5) "Gibbons v. Ogden" (1824) 23 U.S. 1.

(6) En este caso se debió dirimir el conflicto entre una ley del Estado de Nueva York, que acordaba a Robert Livingston y Robert Fulton la exclusividad de operar el transporte en embarcaciones de vapor, y una ley federal, que permitía el comercio de cabotaje a los barcos debidamente inscriptos y autorizados. Ogden, que había obtenido de Livingston y de Fulton la exclusividad del transporte en barcos de vapor entre Nueva York y Nueva Jersey, logró detener judicialmente las actividades de Gibbons, que realizaba ese mismo trayecto con dos barcos de ese tipo. Este invocó la protección de la ley nacional contra la exclusión, creada por la ley local, y el caso fue fallado en favor de ésta en las instancias inferiores, hasta que llegó a la Corte Suprema.

Para hacer prevalecer la ley local, se había entendido la palabra "comercio" como relativa al tráfico, a la compra y venta de mercaderías, que no era comprensiva de la navegación.

94

En este último aspecto—como lo explica Borrajo Iniesta—, “la regulación interjurisdiccional del comercio debía estar exclusivamente en manos de la Federación; pero los Estados no perdían por ello todo el control sobre las actividades con dimensión económica. Subsistía una enorme masa de legislación aprobada por los Estados”.

Según esta doctrina judicial, se le reconocía al Congreso federal una facultad muy amplia para regular el comercio interjurisdiccional.

No por ello, empero, los Estados locales quedaban desprovistos de atribuciones para establecer—dentro de su propio ámbito territorial—sus propias atribuciones para resguardar la salud, la seguridad y la moralidad pública de sus respectivos habitantes, en la medida en que éstas no interfieran el fin que inspiraba a la cláusula de comercio.

Una nueva interpretación judicial de la cláusula de comercio aparecerá con el voto del juez Curtis en “*Cooley v. Board of Wardens*” (1851). Se destacaba en él que el poder de regular el comercio por parte del Congreso de los Estados Unidos no era exclusivo por ser potestad de regular, sino por reglar el comercio entre los Estados. En este fallo se desdeñaba cualquier criterio absoluto a los que se consideraban intrínsecamente imperfectos. La solución tenía que ser relativista y pragmática.

En el caso “*Wabash Railways v. Illinois*”, apartándose abiertamente del precedente “*Granger*”, sostuvo que una ley estatal que limitaba las tarifas de los ferrocarriles no podía ser aplicada a transportes que iban más allá de la frontera de un Estado.

A partir de ese fallo, el Congreso comienza a legislar fuertemente inspirado en los alcances amplios de la cláusula de comercio. En 1890 se sanciona la Ley Sherman, que prohibía toda actuación restrictiva de la competencia en el comercio entre Estados.

El apogeo de la interpretación lata de la cláusula de comercio sobrevendrá en 1937, a impulso de la nueva legislación promovida por el presidente F. D. Roosevelt en su programa de amplia participación en la economía, elaborado para superar la gran depresión de 1930.

En 1937, empero, el tribunal supremo le dará un amplio respaldo al sostener la constitucionalidad apoyada en la cláusula de comercio de la Ley de Relaciones Laborales Nacionales, aplicada a una empresa siderúrgica que ni siquiera realizaba comercio interestadual en sentido estricto (7).

b) Regulación en el Derecho nacional

El art. 75 inc. 13 de la Constitución Nacional, establece que compete al Congreso Federal “...reglar el comercio con las naciones extranjeras, y de las provincias entre sí...”.

(7) “*N.L.R.B. v. Jones & Laughlin Steel Corp*” (1937).

Las modificaciones introducidas por la reforma constitucional de 1994 son de escasa trascendencia. Se reemplaza reglar por reglamentar y se suprime la frase “marítimo y terrestre”, con lo que queda incluido también el transporte aéreo. Esta modificación es correcta porque es del caso destacar que el comercio no es marítimo, ni terrestre, ni aéreo. Estos calificativos corresponden al transporte, que sólo es uno de los actos de comercio (8).

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dirimió la cuestión al resolver el caso: “*S.A. Mataldi, Simón Ltda. v. Provincia de Buenos Aires*” de 1927, admitiendo que el Estado federal puede establecer impuestos indirectos por tiempo indeterminado, junto con los provinciales de la misma naturaleza. A esta conclusión arribó haciendo una interpretación armónica de los arts. 4º y 67 inc. 2 (actual 75 inc. 2 modificado). Estos impuestos indirectos internos son entonces de naturaleza concurrente y pueden ser establecidos tanto por el Estado federal como por las provincias, conjunta o alternativamente (9).

Spisso, en un análisis que compartimos en lo sustancial, distingue tres etapas en esa evolución jurisprudencial (10):

1. La primera, que se extiende desde la instalación de la Corte, en 1863, hasta 1966. Es la doctrina tradicional de la Corte que admite, respecto del comercio interjurisdiccional, el ejercicio de facultades impositivas por las provincias en la medida en que no condicionen su curso, no discriminen en su contra, o no lo sometan a regulaciones múltiples que obstruyan, obstaculicen o entorpezcan una determinada política nacional. En esta época, empero, se les negó a las provincias el ejercicio de atribuciones tributarias en materia de transporte interjurisdiccional (11).

2. La segunda etapa, que se desarrolla desde 1966 a 1973, adopta un criterio rigurosamente centralista al vedar, por lo general, el ejercicio de facultades impositivas a las provincias respecto del comercio interjurisdiccional.

3. La tercera etapa, que se inicia en 1973, marca un retorno renovado a la doctrina tradicional de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que había abandonado a partir de 1966, pero ahora comprendiendo en este criterio también al transporte interjurisdiccional.

4. CLÁUSULAS DE PROGRESO O PROSPERIDAD

a) Antecedentes históricos

Su origen constitucional se remonta al art. 67 inc. 16 de la Constitución histórica de 1853-60, que hoy la encontramos bajo la nueva numeración del

(8) EKMEKDJIAN, MIGUEL A., *Tratado de Derecho Constitucional*, 1997, t. IV, p. 508.

(9) Fallos 149:260.

(10) SPISSE, RODOLFO R., *Derecho constitucional tributario*, 2000, p. 103.

(11) “*S. A. Mataldi, Simón Ltda. c. Provincia de Buenos Aires*” de 1927 (Fallos 149:260) ya citado.

art. 75 inc. 18, con el agregado complementario del inc. 19 incorporado luego de la reforma del año 1994. Ello como potestad del Estado Federal, pero también esta facultad la ostentan las provincias según el art. 107 actual art. 125 de la Constitución Nacional.

La cláusula del progreso no ha sido tomada de la Constitución de EE.UU. como la Cláusula del Comercio (12), sino fue inspirada en el proyecto de Constitución del publicista Juan Bautista Alberdi.

b) Constitución histórica de 1853-1860

Como ya dijimos, de las ideas progresistas de Alberdi ha nacido la cláusula de la prosperidad, que fuera luego regulada por los arts. 67 inc. 16 y 107 (hoy 125) de la Constitución histórica de 1853-60.

En ellos le otorgaba al Estado Federal las facultades de regular lo conducente a la prosperidad del país, al adelanto y bienes de todas las provincias, mediante leyes protectoras de estos fines y por concesiones temporales de privilegios y recompensa (art. 67 inc. 16). Pero estas facultades no eran exclusivas de la Nación, sino que eran facultades concurrentes con las provincias (art. 107).

c) Reforma constitucional de 1994 y el fortalecimiento del constitucionalismo social

Los convencionales constituyentes lejos estuvieron en querer limitar el accionar del Estado en procura de un bienestar general para todos los habitantes, sino por el contrario han ampliado y reformulado el Constitucionalismo Social de Derecho a través de la inclusión de un nuevo inciso 19 del art. 75 y un párrafo agregado al art. 125. Además de los arts. 37, 41, 42 y art. 75 incs. 8 y 23.

Una de las principales falacias del discurso jurídico economicista ("law and economics") (13) ha sido pretender que el texto constitucional es indiferente o neutro a un determinado programa social (14).

Ya la Constitución originaria de 1853-1860 contenía un orden económico determinado, representado fundamentalmente por el ideario alberdiano de la prevalencia de las libertades económicas clásicas. La famosa norma del ex art. 67 inc. 16 (actual art. 75 inc. 18), rotulada por la doctrina como "cláusula del progreso", es —en este sentido— emblemática.

(12) Art. 1º Sección 8 párrafo 3 de la Constitución de EE.UU.: "...El Congreso tendrá facultad... para regular el comercio con las naciones extranjeras, así como entre los Estados Unidos y con las tribus indias..."

(13) También conocida esta corriente en Argentina como "análisis económico del Derecho" (AED).

(14) CARNOTA, WALTER, op. cit.

Podemos afirmar, entonces, que ya la Constitución histórica contenía una "constitución económica", es decir, un modo de ordenación de los recursos humanos y materiales del Estado.

Craso error es argüir que el constitucionalismo clásico era aséptico en punto a las relaciones económicas. La pretendida neutralidad escondía "per se" una toma de posición (15).

El agregado del art. 14 bis realizado en 1957 configuró la aceptación de un "constitucionalismo social de mínima", que encima aparecía impugnado inicialmente por los defectos formales de dicha revisión constitucional, que hizo caso omiso —al darse en época "de facto"— del mecanismo consagrado por el art. 30.

Precisamente, una de las grandes contribuciones de la empresa reformista de 1994 fue tomar como punto de partida o de arranque al art. 14 bis, y mejorarlo con disposiciones que entendemos complementarias (art. 75 incs. 19, 22, 23 y concs., C.N.) (16).

d) Tratados internacionales con jerarquía constitucional

Además de los artículos incorporados en la Constitución Nacional también debemos mencionar lo dispuesto en los tratados internacionales de Derechos Humanos con jerarquía constitucional. Tales son los casos de los arts. 2.1, 13. 1., 13. 2 y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, art. 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica y art. XII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

Sin lugar a dudas los tratados mencionados han efectuado un muy importante aporte a la cláusula del progreso, regulando, ampliando y obligando a los Estados partes a llevar medidas positivas tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacional, en beneficio del bienestar general de todos los países de América.

En un mundo globalizado si se suscitan crisis económicas o políticas en un país las consecuencias serán sufridas en forma inmediata en los estados vecinos y luego en forma mediata al resto del continente, es por ello, que el desarrollo y progreso de sus miembros se basan en la ayuda y cooperación mutua en sus diferentes aspectos económicos, sociales y educativos.

Bajo estas circunstancias uno de los aportes más importantes de los tratados internacionales con jerarquía constitucional, es el derecho inalienable y asequible a la "educación".

Al respecto el art. 13.2. del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales estableció que los Estados Partes que:

(15) CARNOTA, WALTER, op. cit.

(16) CARNOTA, WALTER, op. cit.

- a) la enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible gratuitamente;
- b) la enseñanza secundaria, en sus diferentes formas, incluso la enseñanza secundaria técnica y profesional, debe ser generalizada y hacerse accesible a todos, por cuantos medios sean apropiados y, en particular, por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita;
- c) la enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados, y en particular, por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita;
- d) debe fomentarse o intensificarse, en la medida de lo posible, la educación fundamental para aquellas personas que no hayan recibido o terminado el ciclo completo de instrucción primaria;
- e) se debe proseguir activamente el desarrollo del sistema escolar en todos los ciclos de la enseñanza, implantar un sistema adecuado de becas, y mejorar continuamente las condiciones materiales del cuerpo docente.

Para que este derecho no sea un derecho programáticamente incumplido, el art. 14 compromete a los Estados partes del Pacto a elaborar y adoptar, dentro de un plazo de dos años, un plan detallado de acción para la aplicación progresiva, dentro de un número razonable de años fijado en el plan, del principio de la enseñanza obligatoria y gratuita para todos.

Un aporte importante del Pacto de San José de Costa Rica es el regulado por su art. 26, donde estipula el logro progresivo de la *"plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de sus recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados..."*. Es decir, la obligatoriedad del Estado en la Cláusula del Progreso son los propios recursos de los Estados, porque todo progreso debe desenvolverse sobre la base de sus propios potenciales para que sea genuino y duradero.

5. CLÁUSULA DEL DESARROLLO HUMANO

El art. 75 inc. 19 —como explica María Angélica Gelli (17)— es la compatibilización efectuada entre el progreso y la estabilidad económica con el desarrollo humano en su más amplia aceptación, reuniendo atribuciones que para alguna crítica parecen, en principio incompatibles.

(17) GELLI, MARIA ANGÉLICA, *Constitución Nacional comentada*, Buenos Aires, 2005, p. 694.

Las incógnitas que deparó esta norma son las mismas que recoge el Informe sobre Desarrollo Humano 95 del Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo, al puntualizar la necesidad de armonizar aquellos dos objetivos, con la conclusión de que el crecimiento es condición necesaria pero no suficiente para el desarrollo y se afirma que el desarrollo sin crecimiento no es sostenible en el largo plazo.

Por ello la "cláusula del desarrollo humano" no solo tiende al progreso económico como se encuentra regulado en las cláusulas anteriores sino también requiere un progreso de la persona humana, en sus diferentes niveles de educación (primaria, secundaria y terciaria), salud (mortalidad infantil, índice de mortalidad adulta, centros de salud), laboral (índice de desocupación, acceso a un trabajo digno, salario, obra social, jubilaciones, asistencias laborales).

Es decir, toda estadística que se elabore sobre el desarrollo además de contener un índice de crecimiento económico y progreso en un país, necesita un índice de crecimiento humano, pero no solo de estas generaciones sino también de generaciones futuras, asemejándose al desarrollo sustentable del art. 41 de la Constitución Nacional, pero como un derecho social sustentable (art. 14, 14 bis y 75 inc. 23 de la CN).

Y si a ello lo consideramos un derecho constitucional le podemos sumar la posibilidad de utilizar el control de constitucionalidad por omisión en aquellos casos en que no se haya instrumentado la equidad y gratuidad en la enseñanza, en el plazo que indica el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

6. A MODO DE CONCLUSIÓN

La Constitución Nacional le ha otorgado al Congreso Nacional la competencia federal para legislar sobre tres cláusulas: 1) la *"cláusula del comercio"* art. 75, inc. 13 (antes, art. 67, inc. 12), 2) la *"cláusula del progreso"* del art. 75, inc. 18 (antes 67, inc. 16) y 3) la *"cláusula del desarrollo humano"*, inc. 19 del mismo artículo (texto 1994). Pero similares facultades se le ha otorgado a las provincias, cuya ampliación regulatoria la encontramos en el art. 125 (anterior 107) —con inclusión de la Ciudad de Buenos Aires—.

Dentro de nuestro federalismo mixto, la Constitución otorga facultades concurrentes y exclusivas, para la Nación, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires —luego de la reforma de 1994—. Con relación a las cláusulas del progreso, las facultades concurrentes son las que han producido mayor cantidad de conflictos judiciales, atento las reiteradas interferencias tanto de las provincias hacia la Nación, como de ésta con las provincias. Y la reforma de 1994 no ha ayudado demasiado para dilucidar dicha problemática.

A nuestro entender, estas políticas de bienestar general deben tener claro que un régimen de promoción industrial o un régimen de fomento con exen-

ción impositiva es una clara reducción en el presupuesto nacional que interfiere en la masa coparticipable con perjuicio para todas las provincias. Es por ello que creemos que dichas políticas deben discutirse en el seno de la Comisión Federal de Impuestos, órgano éste que por su carácter técnico se encuentra en mejores condiciones para dilucidar con mayor claridad todas estas cuestiones. De esta forma no solo robusteceremos al federalismo sino también consolidaremos el crecimiento armónico y solidario de todas las provincias, fortaleciendo los lazos de ayuda y cooperación económica social.

Los límites a estas facultades la podemos dividir en dos: las adjetivas y las sustantivas. Las primeras son las que resultan incompatibles en su formulación legislativa, como pueden ser:

a) Leyes que otorguen concesiones de privilegios sin un límite preestablecido de tiempo; aunque estas sean renovadas por otro período, deberá contener obligatoriamente un plazo de finalización (art. 75 inc. 18).

b) La ley que provee el crecimiento armónico de la Nación y las provincias que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones, cuya cámara de origen sea la Cámara de Diputados (art. 75 inc. 19 párrafo segundo). Como complemento de la primera las segundas hacen al espíritu y contenido de la norma, y esto se desarrolla a través del control de constitucionalidad en la razonabilidad de la norma. Si bien no podrá el Poder Judicial, analizar el mérito o conveniencia de la medida adoptada, sí podrá establecer que la ley federal altera arbitraria e irrazonablemente otros derechos constitucionales (art. 28 de la CN) o limita facultades provinciales más allá de las necesarias para lograr el bienestar general pretendido (art. 125).

Del mismo modo, las provincias no podrán establecer leyes que obstaculicen el ejercicio de las mentadas facultades (75 inc. 18 y 19), que no solo es una obligación de la legislatura su regulación y mejoramiento, sino un derecho de todas las personas en un estado constitucional, social y humano de derecho, cuya obligatoriedad internacional, han transformado a esta cláusula en una de las que más trascendentes y debatidas herramientas constitucionales.

PARTE CUARTA

ORGANIZACIÓN DEL PODER

CAPITULO I.1

PODER LEGISLATIVO

SUMARIO: 1. Introducción. — 2. Antecedentes. — 3. Conceptualización. — 4. Caracterización nacional. — 5. Composición del Congreso nacional. — 6. Funciones del Congreso. — 7. Formación y sanciones de las leyes. — 8. Juicio político. — 9. Poderes expresos de legislación general. 9.1. Económicos y financieros. 9.2. Relaciones exteriores. 9.3. Política cultural, inmigratoria y demográfica. 9.4. Cláusulas del progreso. 9.5. Cláusula comercial. 9.6. Defensa. 9.7. Ley de presupuesto. — 10. Atribuciones especiales. Leyes constitucionales. — 11. Poderes implícitos.

1. INTRODUCCIÓN

El art. 16 de la Declaración francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, del 26 de agosto de 1789, además de requerir una declaración de derechos individuales impone la división de poderes, sin cuya garantía se "carece de Constitución".

En la división de poderes uno de los órganos que cumple mejor la directiva dada por el art. 1º, en relación a la forma representativa, es el Poder Legislativo, si tenemos en cuenta que allí manifiestan su opinión los más variados sectores sociales y políticos de nuestro país.

La ley que es la máxima expresión de la voluntad popular, a través de sus representantes, se caracteriza por el consenso y el análisis argumental de todas las políticas económicas, educacionales, de seguridad y salud, que requiera el Estado.

Además del diseño político general, el Poder Legislativo deberá reglar el alcance de los derechos que se encuentran enunciados explícitamente o implícitamente —art. 33— en la Constitución Nacional.

El constituyente no concibió a los derechos de forma absoluta. Al contrario, el propio art. 14 prevé su regulación por parte del Congreso ("conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio"), dentro de un marco de *legalidad formal*. Agreguemos que el principio de legalidad tiene varias manifestaciones en este tramo de la Constitución: arts. 14, 16, 17, 18 y 19 (1).

(1) CARNOTA-MARANIELLO, *Constitucional de la Nación Argentina*, Buenos Aires, 2007.

Aunque la legalidad es una condición necesaria de la reglamentación, ella sólo no alcanza. Es un recaudo adicional que la misma sea *razonable*.

La razonabilidad se halla contemplada en el art. 28 de la Constitución Nacional, cuando estatuye: "Los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos, no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio" (2).

Configura esta directiva una trascendente valla o limitación al poder público quien, so color de una presunta "reglamentación", no podrá desnaturalizar o destruir el contenido esencial del derecho fundamental en cuestión (3), como hemos visto en anteriores capítulos.

2. ANTECEDENTES

Cuando en "El espíritu de las leyes" Montesquieu desarrolla su tesis sobre la división de poderes, se apoya en "la constitución de Inglaterra". Su reflexión, sin embargo, poco tenía que ver con la realidad normativa de la constitución inglesa, pues usaba dicha expresión en el sentido amplio con que se venía utilizando desde la antigüedad, al modo de Aristóteles, Polibio o Maquiavelo, como modo de ser o configuración del poder en un Estado, sin tomar en cuenta su carácter escrito o consuetudinario, disperso o concentrado (4).

Su punto de perspectiva es el valor fundamental contenido en el Estado: "la grandeza en Roma, la guerra en Lacedemonia", y predica para Inglaterra "la libertad política". Para que haya tal libertad, "el gobierno no debe dar lugar a que ningún ciudadano pueda tener nada de otro", y para ello es preciso que el legislativo esté separado del ejecutivo y a su vez el judicial de ambos. "Si el judicial va unido al poder legislativo, los poderes sobre la vida y la libertad de los ciudadanos serán arbitrarios pues el juez sería el mismo legislador. Si va unido al ejecutivo el Juez estaría revestido de la fuerza de un opresor (5).

Montesquieu sostenía que todo está perdido si el mismo hombre, el mismo cuerpo de personas principales de los nobles o del pueblo ejerciera los tres poderes, hacer las leyes, ejecutar las resoluciones públicas, y juzgar los delitos o las diferencias entre particulares" (6).

3. CONCEPTUALIZACIÓN

Como su denominación lo indica es un órgano cuya atribución específica es legislar, y a través de ella realiza un control político en el cual dichos pro-

(2) *Ibidem*.

(3) *Ibidem*.

(4) PUNTE, ROBERTO ANTONIO, "La constitución inglesa", www.eldial.com.ar.

(5) *Ibidem*.

(6) *Espíritu de las Leyes*, 2ª parte, Libro 11.

yectos legislativos—y los tratados internacionales—no estén en contra de la dogmática constitucional.

Dividido por dos cámaras, mientras que la de diputados representa al pueblo la de senadores hace lo propio con las provincias, es decir, una pertenece al pueblo y la otra a las provincias, aunque esta última representación se ve desdibujada por la llamada partidocracia, al estar más atenta a las miradas partidarias que a las necesidades de cada provincia (7).

4. CARACTERIZACIÓN NACIONAL

La Argentina al ser, como ya indicamos *ut supra*, un Estado federal—mixto como lo llamaba Alberdi—ostenta dos gobiernos: uno federal (arts. 44 a 120) y otro provincial (arts. 121 a 129) (8).

Aunque en el nuevo art. 129 se incluye la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mientras que muchos la asimilan a una provincia más de la Nación argentina, otros la consideran un estado *sui generis* con características propias y particulares.

A la vista del art. 75 inc. 2 párrafo segundo donde no forma parte del acuerdo de la ley convenio como todas las provincias, contrariamente en los párrafos tercero, cuarto y quinto la incluyen dentro de la distribución o de coparticipación, de la transferencia de competencias y del organismo fiscal federal, en las mismas condiciones que la Nación y las Provincias.

Vista la falta de coincidencia entre los diferentes artículos y las particularidades mencionadas, nos inclinamos por la última postura que la considera un estado *sui generis*.

En la reforma de 1994, a los efectos de darle participación a las minorías se le ha incorporado a la Cámara de Senadores un senador más, quedando dos por la mayoría y el restante para la segunda fuerza. Son elegidos en forma directa y conjunta, en una elección popular (art. 54) y duran en sus cargos por un período de 6 años, pudiendo ser reelegibles indefinidamente (art. 56).

Este último aspecto no cumple con la manda republicana de la periodicidad en la función, que resulta una cuestión muy importante en la renovación del cuerpo, y un beneficio directo a la no perpetuidad en los cargos públicos.

5. COMPOSICIÓN DEL CONGRESO NACIONAL

Cabe destacar que de acuerdo con lo prescripto por el art. 44 de la Constitución Nacional, el órgano Congreso se integra por dos Cámaras, una de diputados de la Nación, y otra de senadores de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires.

(7) CARNOTA-MARANIELLO, op.cit.

(8) *Ibidem*.

Se patentiza así la lógica detrás del *bicamarismo* (es decir, la existencia de dos cámaras legislativas) que, como principio rector de nuestra organización parlamentaria consagra el plexo de base. Los diputados representan al colectivo "Nación", mientras que los senadores hacen lo propio con las provincias y la Ciudad autónoma.

Largo sería debatir la conveniencia de que subsista esa división en dos cámaras. Lamentablemente, con la reforma de 1994, el Senado perdió algo de su carácter de órgano de las autonomías provinciales, para venir a funcionar en realidad como la representación de los dos partidos políticos más votados. El artículo 54, en ese sentido, resulta paradigmático.

Pero de ningún modo puede afirmarse que el Senado haya extraviado completamente su carácter *federal*, ni que un mayor control que supone dos cámaras sea desdeñable.

Hay una tendencia en nuestro Congreso a ser reactivo a los pedidos del Presidente de turno. En tal aspecto, la "agenda legislativa" es fijada por el Ejecutivo, y poco o nada es lo que hacen respecto de ella los legisladores más allá de aprobarla o desecharla.

6. FUNCIONES DEL CONGRESO

Paradójicamente, la función más relevante del Congreso que es la legisfante ("hacer la ley") no aparece expresamente nombrada en el elenco del art. 75, más allá de una presencia en la nueva redacción que en 1994 se confirió al inciso 12, y más allá —claro está— del rol que el órgano legislativo desempeña en el capítulo V: "*De la formación y sanción de las leyes*".

Todos los principios, derechos y garantías establecidos por la Constitución son susceptibles de reglamentación legal, a tenor de lo que disponen los arts. 14 y 28 constitucionales. Se fijan allí las pautas de *legalidad* y de *razonabilidad* (ver *supra*).

Al distinguir las funciones de un Parlamento y de un Congreso, según se trate de estructuras parlamentaristas y presidencialistas, respectivamente, Bidegain señala que "*el Congreso debe hacer la ley en un sistema de este tipo y no simplemente debatir y sancionar proyectos en cuya redacción no ha tenido sino participación muy relativa... Debe hacer el estudio a fondo de la situación que requiere un remedio legal, recoger toda la información útil sobre la materia, inclusive —pero no exclusivamente— la que pueda proporcionarle el órgano administrador, y aplicarse, por último, a la redacción de la ley, labor que reclama, además del conocimiento de las leyes fundamentales del idioma y del buen gusto literario (virtudes ambas no muy comunes en nuestros repertorios de leyes), el empleo de una correcta terminología y la aplicación de una buena técnica jurídica*" (9).

(9) V. BIDEGAIN, CARLOS MARÍA, *El Congreso de los Estados Unidos de América (Derecho y Prácticas Legislativas)*, Buenos Aires, 1950, p. 12.

Desafortunadamente, entre nosotros y en muchas latitudes los órganos legislativos se han transformado como ya se dijo en "reactivos", es decir, en limitarse a responder a los proyectos que surgen del Ejecutivo, sin una adecuada ponderación en el resultado final al que se arriba.

7. FORMACIÓN Y SANCIÓN DE LAS LEYES

Varias son las normas constitucionales que se ocupan de esta problemática:

Art. 77. — *Las leyes pueden tener principio en cualquiera de las Cámaras del Congreso, por proyectos presentados por sus miembros o por el Poder Ejecutivo, salvo las excepciones que establece esta Constitución.*

Los proyectos de ley que modifiquen el régimen electoral y de partidos políticos deberán ser aprobados por mayoría absoluta del total de los miembros de las Cámaras.

Art. 78. — *Aprobado un proyecto de ley por la Cámara de su origen, pasa para su discusión a la otra Cámara. Aprobado por ambas, pasa al Poder Ejecutivo de la Nación para su examen; y si también obtiene su aprobación, lo promulga como ley.*

Art. 79. — *Cada Cámara, luego de aprobar un proyecto de ley en general, puede delegar en sus comisiones la aprobación en particular del proyecto, con el voto de la mayoría absoluta del total de sus miembros. La Cámara podrá, con igual número de votos, dejar sin efecto la delegación y retomar el trámite ordinario. La aprobación en comisión requerirá el voto de la mayoría absoluta del total de sus miembros. Una vez aprobado el proyecto en comisión, se seguirá el trámite ordinario.*

Art. 80. — *Se reputa aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto en el término de diez días útiles. Los proyectos desechados parcialmente no podrán ser aprobados en la parte restante. Sin embargo, las partes no observadas solamente podrán ser promulgadas si tienen autonomía normativa y su aprobación parcial no altera el espíritu ni la unidad del proyecto sancionado por el Congreso. En este caso será de aplicación el procedimiento previsto para los decretos de necesidad y urgencia.*

Art. 81. — *Ningún proyecto de ley desechado totalmente por una de las Cámaras podrá repetirse en las sesiones de aquel año. Ninguna de las Cámaras puede desechar totalmente un proyecto que hubiera tenido origen en ella y luego hubiese sido adicionado o enmendado por la Cámara revisora. Si el proyecto fuere objeto de adiciones o correcciones por la Cámara revisora, deberá indicarse el resultado de la votación a fin de establecer si tales adiciones o correcciones fueron realizadas por mayoría absoluta de los presentes o por las dos terceras partes de los presentes. La*

Cámara de origen podrá por mayoría absoluta de los presentes aprobar el proyecto con las adiciones o correcciones introducidas o insistir en la redacción originaria, a menos que las adiciones o correcciones las haya realizado la revisora por dos terceras partes de los presentes. En este último caso, el proyecto pasará al Poder Ejecutivo con las adiciones o correcciones de la Cámara revisora, salvo que la Cámara de origen insista en su redacción originaria con el voto de las dos terceras partes de los presentes. La Cámara de origen no podrá introducir nuevas adiciones o correcciones a las realizadas por la Cámara revisora.

Art. 82. — La voluntad de cada Cámara debe manifestarse expresamente; se excluye, en todos los casos, la sanción tácita o ficta.

Art. 83. — Desechado en el todo o en parte un proyecto por el Poder Ejecutivo, vuelve con sus objeciones a la Cámara de su origen; ésta lo discute de nuevo, y si lo confirma por mayoría de dos tercios de votos, pasa otra vez a la Cámara de revisión. Si ambas Cámaras lo sancionan por igual mayoría, el proyecto es ley y pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación. Las votaciones de ambas Cámaras serán en este caso nominales, por sí o por no; y tanto los nombres y fundamentos de los sufragantes, como las objeciones del Poder Ejecutivo, se publicarán inmediatamente por la prensa. Si las Cámaras difieren sobre las objeciones, el proyecto no podrá repetirse en las sesiones de aquel año.

Art. 84. — En la sanción de las leyes se usará de esta fórmula: El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en Congreso, ... decretan o sancionan con fuerza de ley.

8. JUICIO POLÍTICO

Una de las atribuciones del Congreso de la Nación es la relativa al *juicio político*. Se trata, en realidad, de una función no legislativa, sino de índole materialmente jurisdiccional. Existe una corriente, que compartimos, que indica que el juicio político es un proceso constitucional de contenido político. Esta afirmación, reconocemos, dista de ser pacífica. Las opiniones se dividen entre quienes creen estar frente a un mecanismo eminentemente político de remoción de funcionarios (10), y quienes aún dentro de un contexto político rescatan la necesidad de encarrilar su desarrollo bajo las pautas tutelares del debido proceso y del derecho de defensa.

Hay dos normas constitucionales que son claves. En primer lugar, el art. 53, al referirse a las potestades de la Cámara de Diputados, expresa: "Sólo ella ejerce el derecho de acusar ante el Senado al presidente, vicepresidente, al jefe de gabinete de ministros, a los ministros y a los miembros de la Corte Suprema, en las

(10) Por ejemplo, se ha aclarado que "el Senado es un cuerpo político, al cual de ninguna manera le son asimilables los procedimientos de los tribunales judiciales". V. ARMAGNAGUE, JUAN FERNANDO, *Juicio político y jurado de enjuiciamiento en la nueva Constitución Nacional*, Buenos Aires, 1995, p. 136.

causas de responsabilidad que se intenten contra ellos, por mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones; o por crímenes comunes, después de haber conocido de ellos y declarado haber lugar a la formación de causa por la mayoría de dos terceras partes de sus miembros presentes".

En segundo término, el art. 59 consigna respecto del Senado de la Nación: "Al Senado le corresponde juzgar en juicio público a los acusados por la Cámara de Diputados, debiendo sus miembros prestar juramento para este acto. Cuando el acusado sea el presidente de la Nación, el Senado será presidido por el presidente de la Corte Suprema. Ninguno será declarado culpable sino a mayoría de los dos tercios de los miembros presentes".

Se distinguen con claridad dos fases distintas: la acusadora, a cargo de la Cámara baja, y la estrictamente juzgadora, en manos del Senado.

El art. 53 perfila también quiénes son los sujetos susceptibles de este procedimiento, y las tres causales actualmente subsistentes: "mal desempeño, delito en el ejercicio de las funciones o crímenes comunes". Sobre este último aspecto, repárese que el léxico constitucional viene de la norma originaria, en cuya época se distinguía entre "crimen" y "delito". Hoy en día, y a estos fines, ambos conceptos pueden ser considerados equivalentes.

La norma del art. 60 se encarga de los efectos de la condena. Allí se dispone que el fallo del Senado "no tendrá más efecto que destituir al acusado, y aún declararle incapaz de ocupar ningún empleo de honor, de confianza o a sueldo de la Nación. Pero la parte condenada quedará, no obstante, sujeta a acusación, juicio y castigo conforme a las leyes ante los tribunales ordinarios".

9. PODERES EXPRESOS DE LEGISLACIÓN GENERAL

Es como vimos la tarea más eminente y propia del Legislativo. El famoso inc. 12 del art. 75 atribuye al Congreso:

"Dictar los Códigos Civil, Comercial, Penal, de Minería, y del Trabajo y Seguridad Social, en cuerpos unificados o separados, sin que tales códigos alteren las jurisdicciones locales, correspondiendo su aplicación a los tribunales federales o provinciales, según que las cosas o las personas cayeren bajo sus respectivas jurisdicciones; y especialmente leyes generales para toda la Nación sobre naturalización y nacionalidad, con sujeción al principio de nacionalidad natural y por opción en beneficio de la argentina; así como sobre bancarrotas, sobre falsificación de la moneda corriente y documentos públicos del Estado, y las que requiera el establecimiento del juicio por jurados.

a) Económicos, financieros

Son varias las normas que el art. 75 contiene, referidas a la "constitución económica" (ver supra).

En el campo económico en general, revisten interés los incisos quinto (disponer el uso y enajenación de las tierras públicas), sexto (establecer y reglamentar un banco federal con facultad de emitir moneda), décimo (reglamentar la libre navegación de los ríos interiores) y undécimo (fijar el valor de la moneda, y fijar un sistema de pesos y medidas).

Con relación al tema financiero, sobresalen las facultades impositivas en materia aduanera (inc. 1), la de imponer contribuciones indirectas concurrentemente con las provincias y excepcionalmente las directas (inc. 2), las referidas a la coparticipación federal (incs. 2 y 3), la de contraer empréstitos públicos (inc. 4) y correlativamente la de arreglar el pago de la deuda pública interna y externa (inc. 7) y la de fijar el presupuesto anual de gastos y cálculo de recursos (inc. 8).

b) Relaciones exteriores

Sustancialmente, como se verá *infra*, la conducción y manejo de las relaciones exteriores corresponde al Presidente de la República en su carácter de *jefe de Estado*.

Empero, el Congreso reserva para sí importantes facultades en materia de aprobación de tratados internacionales, que el Presidente previamente ha negociado y firmado. Si el Congreso aprueba el documento, entonces recién allí el Presidente queda habilitado para su ratificación en sede internacional.

Los incisos 22 y 24 del art. 75 en examen, ya tratados en ocasión de estudiar la *supremacía federal*, son prueba elocuente de ello:

Inc. 22. *Aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de Derechos Humanos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; la Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Convención sobre los Derechos del Niño; en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos. Sólo podrán ser denunciados, en su caso, por el Poder Ejecutivo Nacional, previa aprobación de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara. Los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos, luego de ser aprobados por el Congreso, requerirán del voto de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara para gozar de la jerarquía constitucional.*

Inc. 24: *Aprobar tratados de integración que deleguen competencias y jurisdicción a organizaciones supraestatales en condiciones de reciprocidad e igualdad, y que respeten el orden democrático y los derechos humanos. Las normas dictadas en su consecuencia tienen jerarquía superior a las leyes. La aprobación de estos tratados con Estados de Latinoamérica requerirá la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara. En el caso de tratados con otros Estados el Congreso de la Nación, con la mayoría absoluta de los miembros presentes de cada Cámara, declarará la conveniencia de la aprobación del tratado y sólo podrá ser aprobado con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, después de ciento veinte días del acto declarativo. La denuncia de los tratados referidos a este inciso, exigirá la previa aprobación de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara.*

Desde la óptica de la masa de atribuciones del órgano Congreso, las del inciso 22 no son menores, si se piensa que con mayorías agravadas o calificadas puede dotar a instrumentos internacionales de la "jerarquía constitucional". Así lo hizo el Congreso hasta ahora en dos oportunidades desde 1994, como se dijo *ut supra*.

c) Política cultural, inmigratoria y demográfica

Indica al respecto Germán Bidart Campos que "no es raro, entonces, que a la fecha el vocabulario politológico y constitucional haya acuñado y difundido el término 'Estado de cultura', en consonancia con el de 'Constitución cultural', lo que ha servido a muchos autores para introducir en el constitucionalismo contemporáneo la trilogía de una *Constitución política*, una *Constitución económica* y una *Constitución cultural*. Las tres, según nuestro enfoque, hacen de segmentos intracomunicados en la unidad total del ordenamiento jurídico constitucional" (11).

Dentro de ese esquema, la reforma constitucional de 1994 ha sido pródiga en disposiciones que aluden al llamado "multiculturalismo", combinando identidad con pluralidad culturales (12).

Así, el inc. 17 del art. 75 (13) en tratamiento señala estas potestades del Congreso:

Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educa-

(11) V. BIDART CAMPOS, GERMÁN J., "¿Un federalismo cultural?", JA, 2004-III-934.

(12) Bien se ha expresado que "la tutela de la identidad cultural de la comunidad en que el individuo vive asciende al rango de característica esencial del derecho a la identidad personal". V. ROLLA, GIANCARLO, "Las perspectivas de los derechos de la persona a la luz de las recientes tendencias constitucionales", en Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 54, Madrid, septiembre-diciembre de 1998, p. 72.

(13) Ver el análisis de esta cláusula en CARNOTA, WALTER F., "Iguales pero distintos. Los indígenas de cara a la Constitución Nacional", en AA.VV., *Constitución de la Nación Argentina*, Santa Fe, 2003, t. I, ps. 233 y sigtes.

ción bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones.

El inc. 19 también viene a cuento, en la medida en que su segundo y tercer párrafo le atribuyen estas facultades, en el campo de la educación y de la cultura:

Sancionar leyes de organización y de base de la educación que consoliden la unidad nacional respetando las particularidades provinciales y locales; que aseguren la responsabilidad indelegable del Estado, la participación de la familia y la sociedad, la promoción de los valores democráticos y la igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna; y que garanticen los principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal y la autonomía y autarquía de las universidades nacionales. Dictar leyes que protejan la identidad y pluralidad cultural, la libre creación y circulación de las obras del autor; el patrimonio artístico y los espacios culturales y audiovisuales.

Todo ello amén de lo que se verá más adelante en este mismo capítulo en el área del progreso.

En el tema de inmigración, una norma clave es la del art. 25 de la Constitución histórica que dice:

"El Gobierno federal fomentará la inmigración europea; y no podrá restringir, limitar ni gravar con impuesto alguno la entrada en el territorio argentino de los extranjeros que traigan por objeto labrar la tierra, mejorar las industrias, e introducir y enseñar las ciencias y las artes".

Allí se ve condensado el ideario de Alberdi en la temática poblacional.

d) Cláusulas del progreso

Fiel reflejo también del pensamiento de Juan Bautista Alberdi, el texto constitucional primigenio, en el art. 67 inc. 16 (hoy 75 inc. 18) prevé una serie de atribuciones concurrentes del Congreso con las provincias que hacen al progreso y bienestar de la comunidad, como se vio en un capítulo anterior.

Dice esta norma que corresponde al Congreso:

"Proveer lo conducente a la prosperidad del país, al adelanto y bienestar de todas las provincias, y al progreso de la ilustración, dictando planes de instrucción general y universitaria, y promoviendo la industria, la inmigración, la construcción de ferrocarriles y canales navegables,

la colonización de tierras de propiedad nacional, la introducción y establecimiento de nuevas industrias, la importación de capitales extranjeros y la exploración de los ríos interiores, por leyes protectoras de estos fines y por concesiones temporales de privilegios y recompensas de estímulo".

La reforma constitucional de 1994 agregó pautas en materia de desarrollo humano, como cabal expresión del llamado "constitucionalismo post-industrial". Sobre el particular, señala el art. 75 inc. 19, primer párrafo, que es atribución del órgano Congreso:

"Proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social, a la productividad de la economía nacional, a la generación de empleo, a la formación profesional de los trabajadores, a la defensa del valor de la moneda, a la investigación y al desarrollo científico y tecnológico, su difusión y aprovechamiento".

A ello se suma lo que dispone el segundo párrafo de esa norma:

"Proveer al crecimiento armónico de la Nación y al poblamiento de su territorio; promover políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones. Para estas iniciativas, el Senado será Cámara de origen".

e) Cláusula comercial

Como eco de la Constitución norteamericana ("commerce clause") (ver *supra*), nuestro artículo 75 inc. 13 faculta al Congreso a:

"Reglar el comercio con las naciones extranjeras, y de las provincias entresí".

De ese enunciado normativo, se desprende que el comercio intraprovincial es regulado por cada provincia, mientras que el internacional y el interprovincial lo es por el Poder Legislativo de la Nación.

f) Defensa

Las siguientes son atribuciones mentadas por el art. 75 en el área de defensa:

Inc. 25. Autorizar al Poder Ejecutivo para declarar la guerra o hacer la paz.

Inc. 26. Facultar al Poder Ejecutivo para ordenar represalias, y establecer reglamentos para las presas.

Inc. 27. Fijar las Fuerzas Armadas en tiempo de paz y guerra, y dictar las normas para su organización y Gobierno.

Inc. 28. Permitir la introducción de tropas extranjeras en el territorio de la Nación, y la salida de las fuerzas nacionales fuera de él.

g) Ley de Presupuesto

El inc. 8 del art. 75 se refiere al presupuesto nacional, mientras que el inc. 9 se relaciona con los presupuestos provinciales:

Al respecto, al Congreso le incumbe:

Inc. 8. Fijar anualmente, conforme a las pautas establecidas en el tercer párrafo del inc. 2 de este artículo, el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la administración nacional, en base al programa general de gobierno y al plan de inversiones públicas y aprobar o desecher la cuenta de inversión.

Inc. 9. Acordar subsidios del Tesoro nacional a las provincias, cuyas rentas no alcancen, según sus presupuestos, a cubrir sus gastos ordinarios.

Se parte de la base de que es necesario contar con una estimación seria de los ingresos y egresos de la Tesorería Nacional. El acto en donde se plasma ese cálculo se denomina "presupuesto".

Con justeza se ha dicho que el presupuesto es un instrumento de programación económica y social; de gobierno y administración, y es también acto legislativo y documento.

La doctrina ha señalado como principios jurídico-políticos del presupuesto: 1) la competencia o reserva legal en materia presupuestaria (lo aprueba que el Congreso); 2) unidad y universalidad (único documento en donde se vuelca la totalidad de recursos y de gastos); 3) especialidad (la autorización específica existente en el crédito presupuestario pertinente) y 4) temporalidad o periodicidad (cubre un término, generalmente de un año) (14).

Obsérvese que el diseño constitucional es claro en cuanto a las atribuciones presupuestarias.

Sin embargo, la *praxis* ha llevado a una elaboración técnica preparada por el Poder Ejecutivo, limitándose el Congreso a su aprobación o tan sólo a alguna discrepancia puntual. Para peor, en los últimos años se ha delegado en el Jefe de Gabinete la capacidad de reasignar partidas (15).

10. ATRIBUCIONES ESPECIALES: LEYES CONSTITUCIONALES

Como se estudió al analizar la problemática de las *fuentes del derecho constitucional*, las aludidas "leyes constitucionales" son una creación de la doctrina especializada. Con esa denominación, se intenta significar a aquellas normas que si bien son formalmente *leyes* porque emanan del órgano

(14) V. IVANEGA, MIRIAM MABEL, *Principios de la Administración Pública*, Buenos Aires, 2005, ps. 248 y sigtes.

(15) Por ejemplo, véase MARANIello, PATRICIO A., "El proyecto de presupuesto para el año 2005 es el certificado de defunción del sistema presupuestario", en www.eldial.com.

Congreso, regulan *materia o sustancia* constitucional. No tienen una gradación jerárquica mayor al rango de cualquier ley más; empero, versan sobre tópicos de relevante interés institucional. Como se dijo, la ley de ministerios, la de acefalía, la de amparo, la de hábeas corpus, la de hábeas data, la de iniciativa popular, la de consulta popular, la del defensor del pueblo, la del consejo de la magistratura, la del ministerio público, son —entre otros tantos ejemplos— leyes que despliegan instituciones plasmadas en el texto constitucional.

11. PODERES IMPLÍCITOS

El artículo 75 inc. 32 reconoce al Congreso la facultad de:

"Hacer todas las leyes y reglamentos que sean convenientes para poner en ejercicio los poderes antecedentes, y todos los otros concedidos por la presente Constitución al Gobierno de la Nación Argentina".

Hay autores que consideran que, así como la Constitución en su art. 33 (agregado en 1860) detecta la existencia de "derechos implícitos", el texto supremo primigenio pone en cabeza del órgano Congreso estas potestades de singulares características. La norma tiene un equivalente en la Constitución de Filadelfia de 1787. Si bien la redacción dista de ser igual, tanto en Argentina como en Estados Unidos ha dado lugar a una prolífica jurisprudencia.

Cabe destacar que el Congreso es la única autoridad constitucionalmente investida de estas prerrogativas, más allá que la jurisprudencia de la Corte Suprema le ha reconocido al propio Alto Tribunal "poderes implícitos" en salvaguarda de la independencia judicial.

Ahora bien, respecto del Congreso se ha observado con acierto que: "*Nuestros constituyentes originarios incluyeron esta cláusula en razón de superar la imposibilidad fáctica de detallar taxativamente la totalidad de las atribuciones imprescindibles para dotar al Congreso de los medios suficientes para poner en funcionamiento las amplias facultades que le son conferidas*" (16).

Para la consideración de esta temática, viene muy a cuento la distinción entre "fin y medios" en el ejercicio del poder. Los fines son los que la propia Constitución le ha prefijado al Congreso; en tal sentido, la norma no amplía esos objetivos.

Empero, los medios integran un espectro amplio, pero que deben necesariamente guardar "razonabilidad" con la consecución de esas metas ya referidas.

Se han planteado varios frentes de atribuciones implícitas, como ser los poderes punitivos del Congreso, sus potestades investigativas, etc.

(16) V. SPOTA, ALBERTO A. (H.), "El Congreso de la Nación y sus poderes implícitos", en *Revista Jurídica de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales*, núm. 4, Buenos Aires, invierno/primavera de 2001, p. 192.

CAPITULO I.2

RESPONSABILIDAD DE LOS ASESORES TÉCNICOS EN EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE NORMAS LEGALES (1)

SUMARIO: 1. Introducción. — 2. Responsabilidad. a) Concepto y características. b) Clases o tipos de responsabilidad. c) Kelsen y su punto de vista desde la teoría general del derecho. — 3. Distinción entre responsabilidad y obligación. 4. Antecedentes en el derecho comparado. a) Derecho Francés. b) Derecho Alemán. c) Derecho Español. d) Derecho Argentino. — 5. Responsabilidad por error judicial. a) Error legislativo: Evolución Jurisprudencial. b) Recepción jurisprudencial a partir del caso "Bustos" concurrencia del voto del Dr. Zaffaroni. c) Tipicidad en el Derecho Penal. — 6. A modo de conclusión.

1. INTRODUCCIÓN

Los agentes públicos sean estos legisladores, jueces o administradores, son guiados y orientados en sus decisiones por expertos en la materia de que se trate, dado que hoy en día la especialidad ha sido considerada como la mejor forma de llegar a resultados acertados.

Cabe destacar que los jueces habitualmente designan lo que conocemos con el nombre de peritos en determinados asuntos (contadores, ingenieros, médicos, químicos, etc.). En cambio, los funcionarios políticos tienen asesores internos y externos. Los primeros son los que se encuentran dentro de la estructura permanente del organismo y los segundos son convocados a cumplir una función de asesoramiento en ciertas cuestiones que por su complejidad o su importancia escapan al conocimiento de los integrantes de su respectivo personal estable.

Ahora bien, cuando un juez dicta una sentencia por un mal asesoramiento técnico de los expertos, o los legisladores o administradores de sus asesores técnicos ¿cuál sería la responsabilidad que tendrían estos últimos en la sentencia, en los decretos o en las leyes hechas por los funcionarios públicos que en definitiva suscriben esos actos?

(1) Artículo publicado en www.conhist.org, el 16/04/2005.

Esta cuestión ha tenido especial trascendencia debido al fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos: "*Bustos, Alberto Roque c. E.N. y otros s/ amparo*" con fecha 26 de octubre del 2004 (Fallos: 327:4495), sobre el denominado "corralito financiero". En dicha resolución, el Dr. Zaffaroni—quien forma parte de la mayoría, donde ha llegado a la misma conclusión que los otros ministros, pero con argumentos propios—hace expresa alusión a la eventual responsabilidad que les cabe a quienes coadyuvaron en la factura de la ley de intangibilidad de los depósitos bancarios, la que en poco tiempo fue rebasada por las propias variables económicas y financieras.

De todas las consideraciones mencionadas por el Dr. Zaffaroni, podemos extraer la significativa importancia que tiene la responsabilidad de los técnicos que trabajan junto a los funcionarios públicos y el alcance del delito de defraudación por suscripción engañosa de documentos, tipificado por el art. 173 inc. 3 del Código Penal (2).

La temática aquí en tratamiento deviene relevante en el contexto del Estado Constitucional de Derecho, en la medida en que "las constituciones actuales, propias de los estados sociales y de derecho a diferencia de las etapas liberales, necesitan de la actuación permanente del legislador ordinario para el desarrollo de sus preceptos, caracterizados por ser mandatos para alcanzar un mejor nivel de vida social y económico de la sociedad". Es que "la constitución no debe ser un código que abarque a detalle todos los ámbitos que se deseen regular. Por el contrario, solo deben marcar los lineamientos generales y trasladarle la obligación de detallar sus preceptos al legislador ordinario" (3).

Se ha repetido hasta el cansancio que ningún derecho fundamental es absoluto; que, por el contrario, todos son relativos y susceptibles de reglamentación. Los parámetros de ese poder reglamentario son, desde un ángulo formal, el principio de *legalidad*, y desde un plano material, el de *razonabilidad*.

El debido proceso sustantivo, es decir, la reglamentación de los derechos, no sólo se satisface con la primera de las pautas indicadas. El análisis que aquí propiciamos va incluso más allá del control de razonabilidad o de constitucionalidad que incumbe a los jueces respecto de las acciones de los otros poderes del Estado, ya que nos adentramos a analizar productos legislativos *legítimos en sí pero que causan o provocan perjuicio a los derechos de particulares*.

Bajo una perspectiva clásica y anticuada del tema, podría fácilmente catalogarse al proceso de formación y sanción de la ley como una *cuestión política no justiciable*. Después de todo, el *criterio* que adopta el órgano Congreso en

(2) Art. 173 del CP. Sin perjuicio de la disposición general del artículo precedente, se considerarán casos especiales de defraudación y sufrirán la pena que él establece: Inc. 3º) el que defraudare, haciendo suscribir con engaño algún documento.

(3) AMEZCUA, LUIS, "Omisiones legislativas en México", en CARBONELL, MIGUEL (Coordinador), *Derecho Constitucional (Memoria del Congreso Internacional de Culturas y Sistemas Jurídicos Contemporáneos)*, México DF, 2004, ps. 946 y 947.

la adopción de tal o cual ley pertenece a la "oportunidad, mérito y conveniencia" congresionales. La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia argentina ha enfatizado que no se presume ni la inconsecuencia ni la imprevisión en el legislador, lo cual tiene su correlato en el ámbito administrativo con la presunción de validez de los actos decididos en dicha sede.

Por lo demás, la inconstitucionalidad, desde la célebre formulación de Brandeis en adelante, configura la "ultima ratio" del ordenamiento jurídico. Dicho en otras palabras, el intérprete debe agotar todos los intentos de armonización y de conciliación de los preceptos jurídicos involucrados para recién allí llegar a su invalidación para el caso concreto. Es lo que se denomina "teoría de la evitación" (*avoidance doctrine*) (4).

A los efectos de suscitar responsabilidad, no es entonces necesario llegar al umbral (*threshold*) de la previa declaración de inconstitucionalidad de la norma legal. Se ha expresado al respecto que "*existen normas lícitas y legítimas que en sí mismas no son inconstitucionales, pero cuyos efectos pueden, en algún caso, causar daños a los derechos. En estos supuestos el Estado debe responder por su actividad lícita, reparando el daño mediante una adecuada indemnización a favor de quien lo sufre. Por ejemplo, si el acto legislativo constituye ejercicio legítimo de una facultad constitucional (verbigracia, ley que establece un monopolio), dicho acto será legítimo y válido. Pero toda vez que lesione derechos adquiridos de los administrados y no meras expectativas, deberá indemnizarlos. De la misma manera, cuando el Estado expropia, ejerce una facultad constitucional, pero debe indemnizar al propietario a quien se le expropia*" (5).

La producción legislativa se ha visto en los últimos años envilecida en su calidad. Redacciones farragosas y confusas, frases vagas y ambiguas, finalidades poco discernibles, hacen que las leyes, no bien dictadas, requieran de posteriores aclaratorias, o directamente son derogadas, o declaradas inconstitucionales por los tribunales de justicia.

Pese a que los equipos de asesoramiento de los legisladores y de las comisiones del Congreso se han transformado en una "tecnoburocracia" por derecho propio (6), ocupando cada vez más espacio físico de aquél asignado a la planta de la Legislatura propiamente dicha, ello no ha contribuido a una depurada elaboración de la norma legal. Todo lo contrario.

(4) Sobre esta construcción del derecho judicial norteamericano, receptada en variadas latitudes, ver LÓPEZ BOFILL, HÉCTOR, *Decisiones interpretativas en el control de constitucionalidad de la ley*, Valencia, 2004, ps. 235 y sigtes.

(5) V. FERNÁNDEZ CITTADINI, J., "Responsabilidad del Estado por sus actos lícitos", Tesinas de la Universidad de Belgrano, Buenos Aires, 2003, p. 20.

(6) Sobre el rol de la Oficina de Presupuesto del Congreso de los EE.UU. (CBO), véase GOODE, STEPHEN, *The New Congress*, New York, 1980, ps. 168 y sigtes. El papel de los equipos técnicos en el Congreso norteamericano es analizado por PATTERSON, SAMUEL C., "The Semi-Sovereign Congress", en A.A.VV., *The New American Political System*, Washington D.C., 1978, ps. 163 y sigtes.

La forma o estructura de gobierno no es un dato menor al considerar estos asuntos. Loewenstein estima que el principio rector del presidencialismo es la *interdependencia por coordinación*, mientras que el del parlamentarismo es la *interdependencia por integración*.

Resulta ilustrativo, por ejemplo, estudiar el papel de las comisiones legislativas en los Estados Unidos y en Gran Bretaña. Observan Bradshaw y Pring respecto de los primeros que "la efectividad de los comités en la preparación de la legislación ha sido provocada por un número de factores, notablemente la extensión en la cual, a medida que la legislación devino más compleja, fueron capaces de reclutar personal apto para ayudarlos a evaluar el testimonio de expertos de la rama ejecutiva. Sin embargo, el desarrollo de un sistema completo de comités ha permitido disfrutar al Congreso de una posición genuina de coordinación con el Poder Ejecutivo, como lo contempla la Constitución. Hoy la diferencia entre el Congreso como una legislatura auto-contenida y el Parlamento que se limita a criticar, reformar, en ocasiones a rechazar un proyecto de ley, pero sin molestar fundamentalmente al programa legislativo del gobierno como un todo, parece completa" (7).

Ello se ha visto con nitidez en la investigación del escándalo Watergate en la década de los '70, del affaire "Irán-contras" en la de los '80 y del juicio político al Presidente Clinton en la de los '90, entre otras instancias legislativas de averiguación y pesquisa. Contrasta todo ello con un rol más "digitado" si se quiere de las comisiones del Parlamento británico. Es que sin dudas este sistema ha transmutado de un "gobierno parlamentario" a un "gobierno de gabinete".

A este análisis contribuye Loewenstein, al consignar que "el grado de autonomía e independencia parlamentaria es diferente en cada tipo de gobierno. No es una exageración el decir que el tipo de gobierno de un determinado Estado depende del grado de autonomía interna del que puede gozar efectivamente el parlamento. Los controles más débiles del parlamento sobre el proceso legislativo se dan en Gran Bretaña; el gabinete tiene un monopolio sin fisuras sobre el punto" (8).

Los crecientes procesos de integración regional (v.gr. Unión Europea), por otra parte, han puesto sobre el tapete el planteo de si cabe imputar responsabilidad por errónea aplicación de la masa de reglas derivadas del llamado *derecho comunitario* (9).

En el caso argentino, advertimos cómo con creciente frecuencia el Congreso de la Nación es cada vez más reactivo; tiene cada vez menos iniciativa propia y se limita a convalidar la agenda del Presidente, en detrimento de su

(7) V. BRADSHAW, KENNETH y PRING, DAVID, *Parliament and Congress*, Londres, 1973, p. 264.

(8) V. LOEWENSTEIN, KARL, *Teoría de la Constitución*, Barcelona, 1979, p. 244.

(9) V. BIDART CAMPOS, GERMÁN J., "La responsabilidad del Estado en los Tratados con jerarquía constitucional", en AA.VV., *Responsabilidad por Daños en el Tercer Milenio*, Buenos Aires, 1997, ps. 425 y sigtes.

propia credibilidad institucional. Dentro de este contexto, no es de extrañar que cada vez con más fuerza desde la sociedad civil se abogue (aunque con poca concreción práctica hasta el presente) por el empleo de las formas de la democracia semi-directa que contemplan los arts. 39 y 40 de la Constitución Nacional, agregados por la reforma de 1994.

Bien se ha señalado con relación a nuestro sistema político que "en cuanto al predominio del Ejecutivo en la iniciativa de las leyes, el Parlamento argentino se asemeja al inglés y al francés, aunque algo más atenuadamente... la Asamblea Nacional francesa se ha convertido en una cámara registradora, en el cual el gobierno es quien dispone qué leyes se van a tratar en el orden del día e inicia la mayor parte de los proyectos. Si bien en nuestro país todavía la Comisión de Labor Parlamentaria es quien arma y dispone el orden del día, en los últimos años la gran mayoría de las leyes de carácter estructural han sido iniciadas por el presidente y aprobadas sin mayores modificaciones por el Congreso, tal como ejemplifica el paquete de leyes económicas de 1989/1991, las leyes previsionales y tributarias, etcétera" (10).

Podemos, además, utilizar distintos modelos teóricos (*frameworks*) para analizar la problemática en examen. Así encontramos, entre muchos otros, tres aportes significativos en esta área, como la "teoría de la decisión en sentido estricto", la "teoría de los juegos" y la "teoría de la decisión social". La primera se basa en el siguiente interrogante axial: ¿cómo puede el decisor elegir entre las posibles alternativas de acción que conoce, aquella opción cuyo resultado le prometa, a la luz de sus propios objetivos una maximización de los objetivos a conseguir? Con relación a la segunda, se elige la estrategia que dentro del marco de las reglas del juego y en vista de la ubicación y calidad de los oponentes promete el resultado más favorable. La tercera considera que los jugadores son más bien miembros de un grupo que, a pesar de ser inicialmente competitivos individualmente, aspiran a una decisión común sin tomar en cuenta potenciales conflictos de poder o de amenaza. Se trata de una versión sociológica de la primera, de hondo cariz psicológico.

Desde una mirada constitucional y encontrándonos en el campo de productos legislativos lícitos y constitucionales la pregunta ha formular es si cabe imputar en estas hipótesis la responsabilidad al Estado. Al respecto Agustín Gordillo afirma que "no existe pues, en principio y en el estado actual de la jurisprudencia, responsabilidad del Estado por leyes legítimas aunque ocasionen daños; pero no creemos que pueda categóricamente decirse que 'en nuestro derecho el Estado no responde por los actos legislativos'" (11).

Creemos que, más allá de los subterfugios jurisprudenciales y doctrinales que se observan en nuestro derecho sobre el tema, debe computarse el claro principio rector que dimana del art. 19 de la CN, en cuanto consagra expresa y nítidamente la prohibición de dañar.

(10) V. PELLET LASTRA, ARTURO, *El Poder Parlamentario*, Buenos Aires, 1995, p. 375.

(11) GORDILLO, AGUSTÍN, *Tratado de derecho administrativo*, 6ª edición, t. II, Capítulo XX, p. 30, Buenos Aires, 2003.

108

Además habrá de distinguirse, desde una matriz más teórica, entre *responsabilidad y obligación*, atento a que muchas veces se confunden la aplicación de una y de otra, sin reparar en que sus características y elementos antecedentes y consecuentes son disímiles. Repárese que la obligación es de voluntario cumplimiento y la responsabilidad es de cumplimiento obligatorio.

Por otro lado, para saber si hay responsabilidad tendremos que averiguar: 1) si el sujeto pasivo coincide con la sanción respectiva, 2) si el perjudicado tiene la potestad de accionar ante el hecho dañoso y 3) además si existe una norma que establece sobre el sujeto pasivo alguna sanción (ej. acto coactivo de privación de bienes).

Si bien este tipo de responsabilidad del Estado por actividad normativa fue tratado tangencialmente en el derecho comparado (Francia, Alemania, España, entre otros) en nuestro país no tuvo un tratamiento muy exhaustivo por parte de la jurisprudencia y de la legislación en lo atinente a su regulación específica, con una clara tendencia a la impunidad y evasión de posibles delitos y daños.

Es por todo ello, que la importancia de dar una regulación propia resulta harto necesaria si tenemos en cuenta que la no sanción de un determinado hecho ilícito realizado con dolo o culpa es un acto de impunidad flagrante que empaña considerablemente un Estado de Derecho. Sin descartar un posible comienzo por vía pretoriana con las normativas legales actuales, como ha ocurrido con varios institutos, cuyo punto de inicio podría ser el voto del Dr. Zaffaroni en el *obiter* del caso "Bustos" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

2. RESPONSABILIDAD

a) Concepto y características

La responsabilidad en derecho es la capacidad existente en todo sujeto activo de derecho para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente.

De ahí que *responsabilidad y persona* sean conceptos inseparables e inescindibles. No se puede ser integralmente *persona* sin tener responsabilidad. Su falta o disminución apareja una *capitis diminutio*; un ser irresponsable, aunque sea un ser humano, no es un ser pleno (12).

Siempre la noción de responsabilidad va a estar ligada a la actividad del hombre, individual o colectivamente considerado, por una causa próxima o remota.

(12) CAVAGNA MARTÍNEZ, MARIANO, "Responsabilidad aquiliana del Estado y sus funcionarios", LA LEY, del 27/11/1990.

Tenemos así que todo daño jurídico atribuido a alguien repercute frente a quien deba responder por sus consecuencias jurídico-patrimoniales (13).

b) Clases o tipos de responsabilidad (14)

Existen cuatro clases bien diferenciadas de responsabilidad:

- a) Responsabilidad personal individual (que es la clásica del derecho penal);
- b) Responsabilidad objetiva individual;
- c) Responsabilidad personal colectiva;
- d) Responsabilidad objetiva colectiva (derecho internacional).

Por otra parte, existen distinciones y *niveles* de responsabilidad teniendo en cuenta su intencionalidad. Un sujeto es responsable por dolo cuando ha querido que el acto perjudicial se produzca, mientras que por culpa se produce frente a la omisión de un deber de previsión.

Puede advertirse con nitidez que los supuestos aquí delineados de presunta responsabilidad de los funcionarios en la formación de la ley de intangibilidad de los depósitos es de índole personal en lo que corresponde a los asesores técnicos involucrados, que puede ir desde la responsabilidad penal, pasando por la civil-patrimonial y concluyendo en la meramente administrativa. Como en todos estos casos, cabe plantearse hasta qué punto podría implicar también un traslado de responsabilidad hacia el Estado, teniendo en cuenta que han ayudado a la formación de la voluntad del órgano *pero que no son el órgano propiamente dicho* (v.gr., no son legisladores).

Cabe también preguntarse si el personal legislativo no está comprendido dentro de las previsiones del art. 1112 del Código Civil argentino, cuando estatuye: "*Los hechos y las omisiones de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, por no cumplir sino de una manera irregular las obligaciones legales que les están impuestas, son comprendidos en las disposiciones de este título*" (la norma alude a hechos ilícitos que no son delitos).

Los sistemas jurídicos inspirados en la tradición continental-romanista han seguido un discurso en líneas generales ascendente en la aceptación de las diversas hipótesis de responsabilidad del obrar del Estado.

c) Kelsen y su punto de vista desde la teoría general del derecho

Al respecto, Kelsen (15) dice que existe el hábito de decir que un individuo es responsable de un daño causado por sí mismo o por otro, cuando está

(13) *Ibidem*.

(14) *Ibidem*.

(15) KELSEN, HANS, *Teoría pura del derecho*, 4ª edición, Capítulo VI, Buenos Aires, 2000.

109

obligado a repararlo. Esta fórmula no es correcta, puesto que la obligación y la responsabilidad son, como ya vimos precedentemente, dos nociones totalmente diferentes.

Existe la obligación de conducirse de una manera determinada cuando la conducta opuesta es la condición de la sanción. Hay, pues, identidad entre el sujeto de una obligación y el sujeto de la conducta que forma el contenido de esta obligación. Por el contrario, un individuo es responsable de una conducta determinada (la suya o la de otro) cuando, en caso de conducta contraria, se dirige contra él una sanción (16).

La responsabilidad puede, pues, relacionarse con la conducta de otro, en tanto que la obligación siempre tiene por objeto la conducta de la persona obligada. Además, el individuo responsable es el objeto de la conducta del órgano estatal encargado de aplicarle una sanción, en tanto que el individuo obligado es el sujeto de la conducta que forma el contenido de su obligación. La noción de obligación está ligada a la categoría del hecho ilícito, en tanto que la responsabilidad se relaciona con la sanción. A su vez, hecho ilícito y sanción están relacionados en la regla de derecho por el principio de imputación. Estas son las nociones primordiales de una teoría del derecho (17).

3. DISTINCIÓN ENTRE RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIÓN

Roberto Vernengo (18) expresa que en derecho un acto es obligatorio en la medida en que el acto contrario esté prohibido, y esté prohibida una acción que sea condición suficiente de la sanción.

Ej.:

Matar → Delito.

No matar → Obligación jurídica (acto contrario al hecho jurídico).

En derecho, no hay actos intrínsecamente obligatorios, sino que un acto sólo es calificado como obligatorio por su relación con el acto prohibido que provoca una sanción.

De ahí que Kelsen afirma que, por lo común, el jurista sólo se refiere a deberes y a obligaciones cuando una norma ha sido suficientemente individualizada.

Es responsable en cuanto puede reprochársele una acción de la cual era psicológicamente y físicamente capaz; es responsable por dejar de cumplir el rol social que había asumido.

(16) *Ibidem*.

(17) *Ibidem*.

(18) VERNENGO, ROBERTO J., *Curso de teoría general del derecho*, Buenos Aires, 1986.

La noción de responsabilidad tiene elementos no sólo jurídicos sino también morales. Cuando se es responsable, se responde por los actos que se ejecuten con discernimiento (conocimiento) y voluntad (intención).

Propone Kelsen que "x" es jurídicamente responsable en cuanto "x" es el sujeto pasivo potencial de una sanción, en mérito a ciertas acciones suyas o de terceros.

Es necesario, pues, distinguir frecuentemente en derecho la obligación de la responsabilidad. O mejor dicho el sujeto del deber jurídico del sujeto responsable.

Por ejemplo el padre es responsable por los actos de sus hijos.

Ej.:

- Obligado → Conducta propia.

- Responsable → Conducta propia y ajena.

Hasta aquí hablamos de responsabilidad subjetiva, pero por su parte existe la responsabilidad objetiva, donde el sujeto de ninguna manera podría evitar el hecho que acarrea la sanción.

4. RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS

a) Antecedentes en el derecho comparado

a.1) *Derecho francés*

El primer antecedente que permite la reparación por parte del Estado manteniendo la licitud de la norma que produjo el daño, lo constituye el célebre *arrêt La Fleurette* (14 de junio de 1938), del Consejo de Estado Francés. En el caso, la Sociedad en cuestión fabricaba un producto llamado *Gradine* (una crema compuesta por leche, aceite de maní y crema de huevo) y el Estado había decidido proteger los productos lácteos, prohibiendo producción alguna que no proviniese exclusivamente de la leche. El Consejo de Estado dirimió la contienda iniciada condenando al Estado por las consecuencias del expresado acto legislativo. Al respecto, dijo que "...nada, ni el texto mismo de la ley o en sus antecedentes, ni dentro de todas las circunstancias del asunto, permiten pensar que el legislador ha querido hacer soportar al interesado una carga que no le incumbía normalmente; esta carga, que fue creada dentro del contexto general, debe ser soportada por la colectividad..." (19). Cabe destacar que el Consejo, "ante el silencio de la ley y por aplicación de los principios generales del derecho, acuerda indemnización" (20).

(19) ABERASTURY, PEDRO, "Responsabilidad del Estado por actividad normativa", en AA.VV., *Responsabilidad del Estado y del funcionario público*, Buenos Aires, 2001, p. 123.

(20) V. DE ESTRADA, JUAN RAMÓN, "Responsabilidad del Estado por actos legislativos y discrecionales (Fundamento y límites de la responsabilidad por la actividad estatal conforme a Derecho)", ED, 102-840.

Si bien este caso solamente se refiere a un único damnificado (la empresa actora, que era la que fabricaba dicho producto), existe con posterioridad una decisión posterior caratulada *Ville D' Elbeuf* del 15 de julio de 1959, que trata sobre las leyes intervencionistas del estado francés que persiguieron frenar el alza del costo de vida.

a.2) Derecho alemán

En Alemania el particular debe soportar a través de reglamentaciones ciertas restricciones, sin posibilidad de ser resarcido y por el carácter social que contiene el patrimonio. La excepción a esta regla la constituye un concreto detrimento en la propiedad que signifique un perjuicio anormalmente grave y especial (21).

Ya en su momento Mayer en célebre obra planteaba que la actividad estatal "no ocurre sin que los individuos sufran algunos perjuicios, pero ellos entran en las condiciones de existencia del Estado al cual los individuos pertenecen... Pero a partir del momento en que esos principios afectan a un individuo de manera *desigual y desproporcionada*, empieza a actuar la equidad, y cuando el perjuicio se traduce en un daño material... habrá lo que se llama el *sacrificio especial*... que debe indemnizarse" (22).

En uno de los primeros fallos la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Alemán conocido como la entrega del ejemplar obligatorio (23), había dispuesto la inconstitucionalidad de la Ley de Hessen que estipulaba la obligatoriedad de la entrega de un ejemplar gratuito a la Biblioteca provincial.

a.3) Derecho español

Al respecto, señala Alberto Bianchi que "*España ha sido el país de Europa donde más se vio demorado el proceso de admisión de la responsabilidad del Estado, aun cuando —justo es reconocerlo— ha logrado hoy una equiparación total con su vecina, la República Francesa, especialmente a partir del dictado de la Constitución de 1978, que ha dedicado varias disposiciones a esta temática, llegando a consagrar incluso el principio de la responsabilidad por acto judicial*" (24).

El art. 139.3 de la Ley de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común establece: "*Las Administraciones Públicas indemnizarán a los particulares por la aplicación de actos legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos y que éstos no tengan el deber jurídico de soportar, cuando así se establezcan en los propios actos legislativos y en los términos que especifiquen dichos actos*".

(21) ABERASTURY, PEDRO, op. cit., p. 125.

(22) V. MAYER, OTTO, *Derecho Administrativo Alemán*, Buenos Aires, 1954, t. IV, p. 217.

(23) BverfGE 58, 137.

(24) V. BIANCHI, ALBERTO B., *Responsabilidad del Estado por su actividad legislativa*, Buenos Aires, 1999, p. 95.

Dicha norma ha permitido avanzar a la jurisprudencia del Tribunal Supremo y, sobre la base de la "teoría del sacrificio especial", ha otorgado indemnizaciones, por ejemplo, en el caso de la eliminación de cupos de pesca exentos de derechos arancelarios con motivo del tratado de adhesión de España a la Comunidad Europea, fundándose además la reparación aludida en el hecho de que la normativa anterior había sido prorrogada seis días antes de la firma del Tratado (esa corta distancia temporal evoca los escasos meses transcurridos entre la ley de intangibilidad de los depósitos y la legislación de emergencia contraria en la Argentina hacia fines de 2001 y comienzos de 2002).

Tal como indica Bianchi, "para determinar la existencia de responsabilidad por acto legislativo, el Tribunal Supremo español se basa en el principio de confianza legítima y maneja criterios tales como el grado de previsibilidad, transitoriedad, existencia o inexistencia de medidas compensatorias, efectos favorables emanados para los demandantes de la propia regulación en cuestión, etc., analizados desde un punto de vista de equidad, razonabilidad y proporcionalidad, en sintonía con la moderna jurisprudencia comunitaria" (25).

No todos los autores, empero, son contestes en el impacto positivo de ese texto legal. Así, expresa Clavero Arévalo: "Ciertamente que la responsabilidad por daños que ocasiona el legislador acaba de tener una merma tremenda con la ley 230/92, con la que se regula el régimen jurídico de las administraciones públicas y el procedimiento administrativo común frente a una jurisdicción avanzada del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, pues ha establecido *que sólo responderá el legislador cuando el propio legislador así lo establezca*, con lo cual pues se ha mermado enormemente la posibilidad de exigir responsabilidad" (26).

En España, en definitiva, los supuestos se vinculan más que nada con la ley expropiatoria; cuando la ley ha sido declarada inconstitucional y su aplicación ha originado perjuicios económicos, y cuando los resultados de su aplicación ameritan en definitiva algún grado de compensación.

a.4) Reino Unido

Se ha comprobado que "el sistema inglés, basado en la actualidad en las disposiciones establecidas en la *Crown Proceedings Act* de 1947, tiene como elemento esencial la ilegalidad de la actuación pública causante del daño" (27).

(25) V. BIANCHI, ALBERTO B., *Responsabilidad del Estado...*, op. cit., ps. 105/106.

(26) V. CLAVERO ARÉVALO, MANUEL, "Debate sobre la Responsabilidad Civil de la Administración Pública", en GARCÍA DE ENTERRÍA, EDUARDO, y otro (Dirs.), *El Derecho Público de fines de siglo (una perspectiva iberoamericana)*, Madrid, 1997, p. 810; énfasis agregado.

(27) V. ORTEGA ALVAREZ, LUIS, "La Responsabilidad Civil de la Administración Pública", en GARCÍA DE ENTERRÍA, EDUARDO, y otro (Directores), *El Derecho Público de fines de siglo*, op. cit., p. 769.

Dicha norma devino central en el recorte de la prerrogativa regia, y "removió exenciones anómalas que disfrutaba la Corona en el litigio civil" (28). Concretamente, se posibilitó la articulación de demandas a los departamentos gubernamentales en materia contractual y de ilícitos civiles, dejando indemne al monarca en sí.

El *Common Law*, tanto en Gran Bretaña como en Estados Unidos, ha desarrollado la noción a partir de la idea de "*taking of property*", con lo cual se vuelve a relacionar al instituto con el de la expropiación.

a.5) República Bolivariana de Venezuela

Si bien una lectura ceñida del art. 140 de la Constitución de 1999 parecería sugerir una responsabilidad acotada al ámbito administrativo, ello es desmentido por la Exposición de Motivos de la ley fundamental.

En efecto, el texto supremo afirma: "El Estado responderá patrimonialmente por los daños que sufran los particulares en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea imputable al funcionamiento de la administración pública".

La aludida Exposición, empero, aclara que "en las disposiciones generales, se establece bajo una perspectiva de derecho público moderna la obligación directa del Estado de responder patrimonialmente por los daños que sufran los particulares en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea imputable al funcionamiento, normal o anormal, de los servicios públicos y por cualesquiera actividades públicas, administrativas, judiciales, legislativas, ciudadanas o electorales, de los entes públicos o incluso de personas privadas en ejercicio de tales funciones".

b) Derecho argentino

b.1) Responsabilidad por error judicial

En las últimas décadas se trabajó en la Argentina la noción de *error judicial*. De una interpretación extensiva de la manda del art. 1112 del Código Civil citado, se ha pasado al art. 10 de la Convención Americana de Derechos Humanos (o "Pacto de San José de Costa Rica") que concretamente estipula: "*Toda persona tiene derecho a ser indemnizada conforme a la ley en caso de haber sido condenada en sentencia firme por error judicial*".

Según la doctrina especializada, el error alcanza a "todas las equivocaciones, actos de mala praxis; apartamientos o irregularidades, sean cuales fueren los motivos para equivocarse" (29).

(28) V. MARSHALL, GEOFFREY, "The Constitution: Its Theory and Interpretation", en BOGDANOR, VERNON (Editor), "The British Constitution in the Twentieth Century", Oxford, 2004, p. 55.

(29) V. MOSSET ITURRASPE, JORGE, *El Error Judicial*, Buenos Aires y Santa Fe, 1999, p. 14.

b.2) Actos normativos: Evolución jurisprudencial

En líneas generales, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sido restrictiva en la materia, en la medida en que inicialmente aceptó la teoría alemana del "perjuicio especial" (30), que ya fue explicado precedentemente, y que admite la responsabilidad del Estado en estos casos solo si hay enriquecimiento sin causa a favor de la administración (31).

Por vía de principio el Alto Tribunal ha sostenido la irresponsabilidad del Estado cuando éste ha ejercido razonablemente sus poderes propios (32), ya que ha considerado que el ejercicio de tales poderes no puede ser fuente de indemnización aun cuando traiga aparejados perjuicios, porque, de lo contrario, el respeto con semejante extensión de las garantías individuales podría detener la actividad gubernativa (33).

También se ha dicho que es particularmente severa la aplicación de los principios de derecho administrativo que hacen a las consecuencias patrimoniales de la revocación por la administración de un acto de alcance general y a la responsabilidad por actos estatales normativos (34).

b.3) Recepción jurisprudencial por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir del caso "Bustos". Voto del Dr. Zaffaroni

Esta cuestión ha tenido especial trascendencia debido al fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos: "*Bustos, Alberto Roque c. E.N. y otros s/ amparo*" con fecha 26 de octubre del 2004, sobre el denominado "corralito financiero".

En dicha resolución, el Dr. Zaffaroni —quien forma parte de la mayoría donde ha llegado a la misma conclusión que los otros ministros, pero con argumentos propios— en el considerando cuarto de su voto expresa "... la llamada ley de intangibilidad de los depósitos bancarios, en cierto momento parece haber tenido en cuenta de preferencia el efecto que producían en el público y no una seria intención de proceder a su cumplimiento, puesto que éste era imposible en el momento de la sanción, como se deduce por el curso posterior de los acontecimientos..."

"... En efecto, una ley que asegura esa intangibilidad casi en vísperas del agotamiento de un proceso traducido en insolvencia y cuya situación no podría ser desconocida para los técnicos que intervenían, aunque la desconocieran los legos en materia económica, se aproxima mucho a la preparación de una defraudación de proporciones colosales. Todo indica que buscaba el efecto de mantener y reforzar en un sistema bancario que estaba al borde del colapso..." (la cursiva no forma parte de la sentencia).

(30) Fallos 180:107. Caso "Establecimientos Americanos Gratry".

(31) Fallos 245:246.

(32) Fallos 258:323.

(33) Fallos 249:259.

(34) "Revestek SA c. BCRA", sentencia del 15 de agosto de 1995, Fallos: 318:1531.

112

"... Por ello, corresponde extraer testimonio de la presente sentencia y remitirlo al señor Procurador General, para que en su ámbito y con el equipo técnico idóneo, proceda a investigar la *eventual responsabilidad penal de los técnicos que intervinieron en el proceso productor del estado de necesidad mencionado y en especial en la citada ley* quienes no podían ignorar la situación y contexto en que la misma se sancionaba. Sería inadmisibles que los tribunales sometiesen a juicio al estafador que vende el incauto una máquina de fabricar dólares y que no se pusiese en movimiento frente a quienes pretendieron venderle el ingenio a toda la sociedad Argentina..." (la cursiva no pertenece a la sentencia).

c) Tipicidad en el derecho penal

Aquí analizaremos uno de los aspectos más interesantes y debatidos en derecho en torno a la responsabilidad de los funcionarios públicos, en la inteligencia de que ellos tienen con los ciudadanos un deber no sólo moral sino también un correlato en el terreno del derecho en sus distintas fases sancionatorias.

Al respecto, debemos tener presente que el acto obligatorio de los gobernantes como toda acción de ese tipo se configura omitiendo realizar el acto que es condición antecedente de la sanción, es decir, si el incumplimiento de la obligación es un acto ilícito.

La suscripción engañosa de documentos por parte de los funcionarios públicos a los órganos decisorios de poder, es un delito tipificado en el art. 173 inc. 3 del Código Penal donde la acción típica consiste en defraudar haciendo suscribir en forma engañosa, es decir con dolo, un documento público o privado de cualquier forma. Se trata de un delito de medios y no de resultados, ya que, tan solo basta la suscripción del documento para la consumación del delito, sin requerirse la producción del daño causado.

Ahora bien, para poder establecer la responsabilidad en el funcionario público y luego obtener la reparación de dicha conducta, resulta indispensable comprobar la relación entre el acto generador del daño, su imputación al Estado, la existencia del particular perjudicado y la conexión causal entre todos estos supuestos.

5. A MODO DE CONCLUSIÓN

En atención al desarrollo de nuestra jurisprudencia, se advierte la patente necesidad de una legislación específica, o bien de una reforma de la Constitución (tal como aconteció en Venezuela en el año 1999), que contemple orgánicamente al error en todos los actos estatales, y que siempre que se produzca un daño (sea a título de error, de dolo o de culpa) haya obligación de reparar. Así como el art. 10 "in fine" del Pacto de San José de Costa Rica consagra al instituto del error judicial (hoy con jerarquía constitucional a la luz del art. 75

inc. 22 de la *lex fundamentalis*), y la ley 19.549 al error y al dolo en el ámbito del acto administrativo (art. 14), deben regularse hipótesis de similares vicios por parte del Congreso cuando irroguen o traigan aparejado daños a los derechos fundamentales de las personas.

Acotemos que el fundamento de esta responsabilidad por actos legislativos es el mismo de la responsabilidad extracontractual del Estado en general.

Las dificultades del tema estriban en que estamos en un terreno fronterizo de responsabilidad, entre esferas lícitas (en donde se pudo actuar asesorando de buena fe con datos equívocos) e ilícitas (donde hubo culpa o dolo).

Cabe examinar, tal como lo hace el juez Zaffaroni en el caso "Bustos", si las conductas de los equipos técnicos que ayudaron a elaborar la ley de intangibilidad de los depósitos (35) no se encontrarían comprendidas en las previsiones penales vistas anteriormente (art. 173 inc. 3 del CP) que llevan a dicho magistrado en el considerando cuarto de su voto a propiciar la remisión del testimonio de la sentencia a la Procuración General de la Nación en su carácter de cabeza del Ministerio público fiscal, titular máximo de la pretensión punitiva del estado (art. 120, C.N.).

La importancia del asesoramiento técnico en el Congreso ha sido enfatizada por Haro, quien señala agudamente que *"la problemática que la Constitución ha aprehendido requiere, para elaborar las soluciones adecuadas, la asistencia técnico-científica, sustancial o de fondo. Aquella preocupación está dirigida al meollo de los contenidos normativos, a las soluciones políticas que desde la Ley, el Congreso prevé para superar las dificultades en los diversos sectores, todo lo cual exige la apoyatura de un competente consejo de expertos"* (36).

Cabe recordar con Alberto Bianchi que la responsabilidad del Estado por actos legislativos fue al igual que su antecesora en el tiempo la derivada en los actos judiciales, una de las últimas en aparecer, y considera esa circunstancia como una comprensible consecuencia de la "teoría de la inmunidad soberana" a la vez que una paradoja, ya que la responsabilidad legislativa del Estado tiene en nuestro país fundamento constitucional al proscribirse el denominado "sacrificio especial" (37).

Cada vez son más las parcelas de la actividad pública que intentan ser sometidas al control y a la supervisión de los órganos competentes. Al respecto, cabe afirmar que mal puede darse una *teoría de la democracia* sin una adecuada *teoría del control*. Estos últimos se enlazan con las nociones tan

(35) Desde un ángulo de la responsabilidad por actividad lícita, concretamente por política económica, recuérdese la implementación del plan "Bonex" en el año 1990, lo cual fue estudiado en su momento por ALTERINI, ATILO A., *Lesión al crédito y responsabilidad del Estado (Por injerencia en los plazos fijos bancarios)*, Buenos Aires, 1990.

(36) Subrayado original. V. HARO, RICARDO, *Constitución, poder y control*, México D.F., 2002, p. 33.

(37) BIANCHI, ALBERTO, op. cit.

difundidas últimamente de "responsiveness" y de "accountability" que sirven hoy para legitimar a cualquier sistema político que se precie de democrático.

El camino iniciado por la concurrencia del juez Zaffaroni en el caso "Bustos" en este sentido revela el comienzo de un proceso que, cimentado en las mejores construcciones de la teoría general del derecho, contribuirá decisivamente a nuestro criterio a la consolidación del Estado Constitucional del Derecho.



CAPITULO 1.3

EL DEFENSOR DEL PUEBLO (OMBUDSMAN)

SUMARIO: 1. Introducción. — 2. Antecedentes históricos. — 3. Derecho comparado. a) Suecia. b) Finlandia. c) Dinamarca. d) EE.UU. e) Gran Bretaña. f) Francia. g) Italia. h) España. — 4. Regulación nacional y provincial. — 5. Atribuciones y funciones. — 6. ¿Cómo iniciar una queja? — 7. ¿Es la verdadera voz del pueblo? — 8. Competencia. — 9. Responsabilidad. — 10. Conclusión.

1. INTRODUCCIÓN

Con el fin de mejorar los mecanismos de control entre los tres poderes clásicos de las democracias liberales, así como para combatir la corrupción y hacer más accesible la justicia para muchos sectores de la población, ha nacido el *Ombudsman* (expresión que puede significar algo así como comisionado parlamentario).

Este organismo, para hacerlo más independiente funciona autónomamente, para asegurar la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos declarados en la Constitución ante actos de la administración nacional.

Su inclusión en la reforma constitucional de 1994 constituye un instrumento fundamental para que los ciudadanos puedan defenderse por las lesiones a sus derechos constitucionales, ante las decisiones administrativas que los menoscaban.

La principal función que tiene el modelo típico del *Ombudsman* escandinavo (el hombre que da trámite), es informarse e informar a la sociedad sobre el correcto funcionamiento de la Administración Pública, así como hacer lo posible para impedir la burocratización del Estado, factor activo y muchas veces determinante de la ineficiencia en la prestación de los servicios públicos. Al decir de Gordillo, es un *abogado social*, un activo colaborador de la función correctora e impulsora de la gestión pública.

Las problemáticas más comunes que ha tenido este instituto fueron el alcance de la legitimación procesal y su responsabilidad. En relación a

114

este último y conforme el principio según el cual no existe función pública sin su correlativa responsabilidad, está sujeto al reproche de su gestión. Su responsabilidad se sustenta en sus actitudes personales y la trascendencia de sus actos y son de aplicación para su evolución los principios generales de la misma.

2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS (1)

La historia del Defensor del Pueblo, en el mundo, comienza en Esparta y Atenas, donde los "Efloré" y los "Euthynoi" respectivamente se dedicaban a controlar las actividades de los funcionarios del gobierno y las actividades municipales. Más tarde, en la China de la dinastía Han, el Emperador destacó un funcionario denominado "Yan", para que ejerciera un contralor sistemático y permanente destinado a la supervisión de la administración imperial y sus funcionarios, recibiendo las peticiones del público contra lo que se denominaban "injusticias administrativas".

Por su parte, en el Imperio Persa, el rey Ciro encargó al "O Olho de Rei" el ejercicio de un contralor sobre la actividad de todos los funcionarios.

Tiempo después, en el siglo XV, el Consejo de los Diez, en Venecia, con probada eficacia controló los excesos burocráticos de la ciudad.

En el siglo XVI, el *Gran Senescal de Suecia*, como verdadero inspector de los tribunales de justicia, exponía ante el rey las anomalías que advertía en la administración de justicia, constituyéndose así en el predecesor del control administrativo que ejercería el Ombudsman.

En efecto, fue en Suecia donde nace la figura del Ombudsman o Defensor del Pueblo tal como hoy en día la conocemos, con sus actuales características, institucionalizándola en su constitución en el año 1809 luego de una disputa entre el rey y el parlamento.

Cuando el régimen autoritario cedió paso a una monarquía parlamentaria, se delimitaron las atribuciones de las tres funciones del Estado, creándose un Ombudsman representante del Parlamento, al que se denominó como *Justitie Ombudsman*.

Se le encargó el control de la observancia de las leyes por parte de los tribunales y funcionarios, facultándolo para demandar ante la Justicia, a quienes en el ejercicio de su función hubieren, por parcialidad, favor o cualquier otro motivo, cometido ilegalidades o descuidado el correcto desempeño de los deberes propios de su cargo. En su carácter de representante o comisionado del Poder Legislativo, tutelaba los derechos, garantías e intereses de los habitantes.

(1) <http://www.defensor.gov.ar>.

3. DERECHO COMPARADO

"Ombudsman" se llamó en Suecia; "Canciller de Justicia" en Finlandia; "El Contralor del Estado" en Israel; "Proveedor de Justicia" en Portugal; "Mediador" en Francia; "Defensor Cívico" en Italia; "Comisionado Parlamentario" en Gran Bretaña; "Comisión Nacional de Derechos Humanos" en México (2); "Procuraduría de los Derechos Humanos" en Costa Rica y "Defensor del Pueblo" en España y Argentina, entre otros.

Institucionalmente, nació con la Constitución Sueca de 1809, y luego fue adoptado en:

- Finlandia (1919),
- Dinamarca (1953),
- Noruega (1952),
- Nueva Zelanda (1962), está inspirada en el modelo danés.
- EE.UU (1966),
- Gran Bretaña (1967),
- Francia (1973),
- Canadá en ocho provincias desde 1967 y 1975.
- Israel (1971).
- India (1971).
- Italia (1974).
- España: la figura está establecida en la Constitución de 1978, que en gran medida es fuente de la incorporación en nuestra reforma de 1994.

Con distintas denominaciones y comienzos temporales, esta institución ha adquirido una relevancia trascendental en el movimiento constitucional contemporáneo, y ha servido para darle transparencia a la función pública.

a) Suecia

A 1713, en Suecia, como se dijo, se remontan sus antecedentes históricos. También conocido como *Ombudsman* o *Justitie Ombudsman* (Ombudsman para la justicia), este instituto remoto nació para dar respuesta a la Corona Sueca en su necesidad de vigilar el funcionamiento del Consejo Real.

(2) Esta comisión tiene la particularidad de ser designada por el Presidente de la República —como en Argentina antes de la reforma constitucional— y forma parte del Poder Ejecutivo. No tiene poder sancionador y representa al gobierno de la República ante organismos internacionales gubernamentales y no gubernamentales de derechos humanos.

Recién en 1809 se lo incluye en su constitución, dependiendo del Parlamento. No formaba parte de la administración y su función primordial era ser imparcial, versado en derecho y con experiencia como juez para fiscalizar las decisiones de los tribunales judiciales y controlar la actividad de la administración pública.

El primer *Ombudsman* sueco dijo que su función sólo depende de la ley. En ese país escandinavo, quedó claro que la relación con el parlamento se limita: a) a sujetarse a las instrucciones generales —y por ningún motivo a indicación alguna en su caso concreto—; b) informarle anualmente de sus actividades (3).

Si bien la figura nació en Suecia, recién adquirió virtualidad y difusión después de finalizada la Segunda Guerra Mundial.

b) Finlandia

Por sus innumerables muestras de eficacia, luego fue adoptada por otro país escandinavo, Finlandia, quien lo incluyó en su Carta Magna de 1919, bajo la denominación "*Canciller de Justicia*". El funcionario finlandés debía: velar para que el gobierno cumpliera la ley, acudir a las reuniones del Consejo de Estado, aunque no tenía voto pero sí voz, para dar opinión e informar al Parlamento (art. 47 de la Constitución Finlandesa); también debía vigilar la actividad administrativa.

c) Dinamarca

Dinamarca la incluyó en su Constitución de 1953. Luego de que ese país abriera las puertas del interés internacional por esta figura, sobrevino un período en el que se vio nacer gran cantidad de representantes de tan novedoso medio de control, a lo largo de todo el planeta y con distintos nombres.

Así en el artículo 55 se disponía que la legislación establezca el nombramiento por la Folketing (Asamblea Legislativa Unicameral) de una o dos personas, quienes no podrán ser miembros de la misma, para que vigilen la administración civil y militar del Estado.

d) Estados Unidos

Tuvo su comienzo en el año 1966. En total son 39 *Ombudsmen*. En virtud del sistema federal de los Estados Unidos, debe existir un *Ombudsman* para cada Estado y otro para el gobierno federal. Dado que el *Ombudsman* sólo hace recomendaciones y no tiene facultades ejecutivas o judiciales, no se dan confusiones en la aplicación pero sí puede ocurrir que en ambos niveles estatal y federal se reciban las quejas. Algo similar ocurre en Australia. La

solución radica en que los *Ombudsmen* están en permanente contacto, remiten la queja a quien corresponde y lo comunican al interesado. El término *Ombudsman* en Estados Unidos se emplea para designar a cualquier tipo de oficina de reclamación.

e) Gran Bretaña

En el año 1967 comienza a funcionar el "Comisionado Parlamentario" (4); para evitar burocratizar y atender un número excesivo de casos, se puso el requisito de que el *Ombudsman* sólo podrá aceptar los casos que envíen los miembros del parlamento. Esto restringe la misión del *Ombudsman*.

f) Francia

Con el nombre de "Mediador" y con un sistema de filtro, similar al de Gran Bretaña, se inició el *Ombudsman* en el año 1973, de manera controvertida.

Actualmente, se ha extendido a una variedad de organismos, como por ejemplo el *Ombudsman* ejecutivo de París, nombrado por el alcalde de la ciudad.

g) Italia

De los países europeos, es donde más se ha desarrollado el concepto, iniciado desde 1974 dentro de los gobiernos regionales. Las presiones y dificultades políticas no son obstáculo para que el *Ombudsman* sea políticamente neutral e independiente. Se basa en el modelo escandinavo y las quejas pueden enviarse directamente, sin intermediario alguno.

h) España

Desde su incorporación en la Constitución de 1978, las Cortes Generales designan al Defensor del Pueblo, para los derechos humanos y supervisión de la actuación de las autoridades administrativas. La investigación de quejas la puede hacer a solicitud de los miembros del Congreso y del Senado, y por su propia iniciativa.

En el artículo 54 de la Constitución Española establece la regla general de competencia: supervisar la actividad de la administración pública, para la defensa de los derechos y deberes fundamentales que la misma establece en su título primero; luego remite a la regulación de la institución a una ley orgánica.

Dicha ley orgánica en su art. 6.1 dispone que el Defensor del Pueblo no estará sujeto a mandato imperativo alguno. No recibirá instrucciones de nin-

(3) FAIREN GUILLÉN, VÍCTOR, *El Defensor del Pueblo —Ombudsman—*, Madrid, 1982, t. I, pp. 167 y 168.

(4) V. BRADSHAW, KENNETH y PRING, DAVID, *Parliament and Congress*, Londres, 1973, p. 374.

...ejecutar sus funciones con autonomía y según su criterio. Conforme el art. 12.1 supervisa las actividades de la Comunidad Autónoma en su ámbito de competencia y puede pedir la cooperación de los órganos similares de las Comunidades Autónomas (art. 12.2.).

Tiene legitimación para interponer recursos de inconstitucionalidad en su ámbito de competencia ante el Tribunal Constitucional (art. 32.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional), amparo y *habeas corpus*.

En el marco legislativo, puede sugerir modificaciones al órgano competente y recomendaciones para la adopción de nuevas medidas a la administración, conforme a los artículos 28.2 y 30.1 de la ley orgánica del Defensor del Pueblo.

4. REGULACIÓN NACIONAL Y PROVINCIAL

Su institucionalización en la República Argentina reconoce antecedentes en la Provincia de San Juan, en la cual en el año 1986, por una reforma constitucional fue introducido el órgano. Con posterioridad, adoptaron la institución las provincias de La Rioja, Córdoba, San Luis, Río Negro, Chaco y Buenos Aires.

Otras provincias como Santa Fe, Tierra del Fuego y Tucumán crearon el órgano, mediante la sanción de leyes, sin otorgarle rango constitucional.

Asimismo, en el orden comunal diversos municipios implementaron la figura del Defensor del Pueblo, destacando entre ellas La Plata, Posadas y Capital Federal, recibiendo en algunos casos como Buenos Aires la denominación de controlador general comunal.

El primer antecedente del Parlamento Nacional data de 1973 mediante la elaboración de un proyecto por el cual se instituye la creación de la Oficina del Comisionado del Congreso, correspondiendo su autoría a Carlos Auyero.

A partir del año 1983, se elaboraron varios proyectos presentados por diversos partidos propiciando algunos la figura del *Ombudsman*, con competencia funcional, política, administrativa y financiera, por entender que debe contar con amplias facultades para solicitar los elementos que crea necesarios a los efectos de realizar la fiscalización que se le adjudica. No debe ser un órgano de gobierno en ejercicio, sino independiente del mismo, contando con autonomía para nombrar a su personal que lo asistirá en sus funciones y ejercer las mismas conforme sus convicciones contando para ello con la asignación de recursos adecuados, los cuales podrán disponer libremente.

Antes de la reforma de 1994 en la República Argentina, en el año 1993 se creó el órgano en el ámbito federal por decisión presidencial mediante el decreto 1786 por el cual funcionaba en la esfera del P.E.N., quien lo designaba.

Luego de la reforma constitucional de 1994 en la ley de *habeas data* (25.326) art. 34, se le da al Defensor del Pueblo la posibilidad de intervenir en forma coadyuvante en toda acción de protección de los datos personales o de *habeas data*.

a) Ley 24.284 modificada por ley 24.379

El Congreso Nacional creó la figura del Defensor del Pueblo con la sanción de la ley 24.284, la cual fue publicada en el B.O. el 06/12/2003.

La ley de mención, en razón de la reforma constitucional, fue modificada por la ley 24.379 la cual creó la Defensoría del Pueblo en el ámbito del Poder Legislativo de la Nación.

El objetivo fundamental de esta institución es el de proteger los derechos e intereses de los individuos y la comunidad frente a los actos, hechos y omisiones de la Administración Pública Nacional (art. 1º).

El Defensor del Pueblo puede iniciar y proseguir de oficio o a petición del interesado cualquier investigación conducente al esclarecimiento de los actos, hechos u omisiones de la administración pública nacional y sus agentes, que impliquen el ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario, discriminatorio, negligente, gravemente inconveniente o inoportuno de sus funciones, incluyendo aquellos capaces de afectar los intereses difusos o colectivos.

Los legisladores, tanto provinciales como nacionales, podrán receptar quejas de los interesados de los cuales darán traslado en forma inmediata al Defensor del Pueblo (art. 14).

Si como consecuencia de sus investigaciones llega al convencimiento de que el cumplimiento riguroso de una norma puede provocar situaciones injustas o perjudiciales para los administrados, puede proponer al Poder Legislativo o a la administración pública la modificación de la misma (art. 27).

El Defensor del Pueblo puede formular con motivo de sus investigaciones, advertencias, recomendaciones, recordatorios de sus deberes legales y funcionales, y propuesta para la adopción de nuevas medidas. En todos los casos, los responsables estarán obligados a responder por escrito en el término máximo de treinta (30) días.

Si formuladas las recomendaciones, dentro de un plazo razonable no se produce una medida adecuada en tal sentido por la autoridad administrativa afectada, o ésta no informa al Defensor del Pueblo de las razones que estime para no adoptarla, éste puede poner en conocimiento del ministro del área, o de la máxima autoridad de la entidad involucrada, los antecedentes del asunto y las recomendaciones propuestas. Sin perjuicio de lo descripto precedentemente, debe incluir tal asunto en su informe anual o especial, con mención de los nombres de las autoridades o funcionarios que hayan adoptado tal actitud (art. 28).

b) Constitución Nacional

La reforma constitucional del año 1994 introdujo, mediante el art. 86; al Defensor del Pueblo determinando su carácter de órgano independiente instituido en el ámbito del Congreso de la Nación, que actuará con plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. Su misión es la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la Administración; y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas. El Defensor del Pueblo tiene legitimación procesal. Es designado y removido por el Congreso con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de cada una de las Cámaras. Goza de las inmunidades y privilegios de los legisladores. Durará en su cargo cinco años, pudiendo ser nuevamente designado por una sola vez.

La organización y el funcionamiento de esta institución serán regulados por una ley especial.

La introducción del Ombudsman en los alcances adjudicados en el art. 86 C.N. responde a la necesidad de contar con una pieza de control del régimen administrador para lo cual es previo diferenciar aquellos países que cuentan con un sistema de gobierno ya establecido definido e históricamente construido de otros caracterizados por ser inestables y alternantes entre sistemas despóticos, tiranías o golpes de estado que por lo general demuestran una administración confusa, sin lineamiento y sin desarrollo organizado.

Por su parte, el art. 43 párrafo segundo de la Constitución Nacional, da legitimación activa para iniciar una acción de amparo colectivo, contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general, al afectado, al *Defensor del Pueblo* y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley, la que determinará los requisitos y formas de su organización.

Es de considerar que si bien dicho funcionario ya existía por ley, la jerarquización del órgano con rango constitucional le da una categoría especial como parte de los Poderes del Estado Nacional.

5. ATRIBUCIONES Y FUNCIONES

Es de señalar que el Defensor del Pueblo se integra a los cuerpos existentes de control, y que con su participación provoca que el ciudadano acceda a novedosas vías de información, generando la participación del mismo, proporcionándole una defensa idónea y original frente a los órganos estatales y sentirse partícipe de la solución de controversias, que en diversas oportunidades lesionan sus intereses.

Constituye una respuesta eficaz y concreta para sostener el equilibrio necesario que debe existir entre el Estado y el ciudadano, resultando absolu-

tamente necesario para su vigencia la internalización de la figura en el ideario social.

Es un órgano independiente y en términos generales puede definirse como una institución unipersonal cuyo titular es elegido por los representantes del pueblo —Poder Legislativo— para prevenir, controlar, mediar, proteger y defender al ciudadano del ejercicio del poder arbitrario, ilegal o injusto al que se lo puede someter desde el Estado o desde las entidades que cumplen funciones públicas dentro del un ámbito general o especial, razón por la cual es imprescindible que tenga independencia funcional y política de quien lo nombra y frente a quien controla.

Es un instrumento con jerarquía constitucional que vigila a la administración ante las quejas del público contra las injusticias y errores administrativos.

Es de resaltar que no se trata de un órgano jurisdiccional; tiene la facultad de investigar, criticar y publicitar las acciones administrativas que violen los intereses de los ciudadanos, pero no el poder de revocarlas.

Su actividad constituye un factor determinante en el control del Estado al equilibrar el peso de los poderes, al fiscalizar la legalidad de la administración, habitualmente sobredimensionada por múltiples funciones.

El Estado, a través del órgano en análisis, refuerza las garantías de tutela de los derechos humanos, posibilitando que el Defensor del Pueblo asuma la defensa procesal del interés lesionado adquiriendo legitimación propia.

En síntesis, la independencia de su función se resguarda por la autonomía que conserva respecto del poder que lo designa y no depende, más allá del informe anual que obligatoriamente presenta, con rendición de su gestión. El informe citado constituye un elemento de contundencia crítica con miras de obtener del funcionario cuestionado una revisión de sus actos, a fin de adecuarlos a los intereses del ciudadano.

6. ¿CÓMO INICIAR UNA QUEJA? (5)

En el art. 19 del texto ordenado de la ley 24.284 y su modificatoria, ley 24.379, se establece que toda queja debe presentarse en forma escrita y firmada por el interesado, con indicación de su nombre, apellido y domicilio en el plazo máximo de un año calendario, contado a partir del momento en que ocurriera el acto, hecho u omisión motivo de la misma.

No se requiere al interesado el cumplimiento de otra formalidad para presentar la queja.

Todas las actuaciones ante el Defensor del Pueblo son gratuitas para el interesado, quien no está obligado a actuar con patrocinio letrado.

En el supuesto caso que la queja se formule contra personas, actos, hechos y omisiones que no están bajo la competencia del defensor del pueblo, o si se formula fuera del término previsto por el art. 19, el Defensor del Pueblo está facultado para derivar la queja a la autoridad competente informando de tal circunstancia al interesado (art. 20).

El Defensor del Pueblo no debe dar curso a las quejas en los siguientes casos (art. 21):

- a) Cuando advierta mala fe, carencia de fundamentos, inexistencia de pretensión o fundamento fútil o trivial;
- b) Cuando, respecto de la cuestión planteada, se encuentre pendiente resolución administrativa o judicial.

Puede rechazar también aquellas quejas cuya tramitación irroque perjuicio al legítimo derecho de tercera persona.

Ninguno de los supuestos previstos impide la investigación sobre los problemas generales planteados en las quejas presentadas.

En todos los casos se comunicará al interesado la resolución adoptada.

Las decisiones sobre la admisibilidad de las quejas presentadas son irrevocables. La queja no interrumpe los plazos para interponer los recursos administrativos o acciones judiciales previstos por el ordenamiento jurídico.

El Defensor del Pueblo debe promover la investigación sumaria, en la forma que establezca la reglamentación, para el esclarecimiento de los supuestos de aquella. En todos los casos debe dar cuenta de su contenido al organismo o entidad pertinente, a fin de que por intermedio de autoridad responsable y en el plazo máximo de treinta (30) días, se remita informe escrito. El plazo puede ser ampliado cuando concurran circunstancias que lo aconsejen a juicio del Defensor del Pueblo.

Respondida la requisitoria, si las razones alegadas por el informante fueren justificadas a criterio del Defensor del Pueblo, éste dará por concluida la actuación comunicando al interesado tal circunstancia.

Puede entregar su queja personalmente o por correo, a la sede central de la Institución: ante el Sr. Defensor del Pueblo de la Nación, en la calle Suipacha 365 Capital Federal o a las oficinas del interior del país. También puede plantear su problema por fax, al (011)-4819-1581; o por correo electrónico, a la dirección: mondino@defensor.gov.ar.

En estos casos, luego de ser evaluada la cuestión, se le solicitará la remisión de la misma por escrito y debidamente firmada, a fin de cumplimentar los recaudos exigidos por el art. 19 de la ley 24.284.

Recibido su reclamo, se le enviará una nota donde se informará el número de actuación y el área que llevará adelante el trámite.

7. ¿CONSTITUYE VERDADERAMENTE LA VOZ DEL PUEBLO?

Para responder a este interrogante es necesario que cuente con independencia:

- 1) **Funcional:** A los efectos de reunir los elementos necesarios a fin de fiscalizar sin interferencias de ninguna especie, por parte de los Poderes del Estado, incluso del mismo Poder Legislativo quien lo ha designado.
- 2) **Política:** Para lograr los objetivos de función es necesario que no revista el carácter de órgano del gobierno de turno, ni de ningún partido político, ni condescendencia con los Poderes del Estado.
- 3) **Administrativa y Financiera:** Es necesario que cuente con la facultad de elegir a sus colaboradores y que sus decisiones las ejerza tomando en cuenta sus convicciones, creencias personales y por otra parte que cuente con recursos necesarios para cumplimentar sus tareas en un marco de libertad en relación a su función, que no podrá ser disminuida por la sola voluntad del P.E.

Su designación debería realizarse democráticamente, recordando que esta elección constituiría la esencia de su independencia, que redundaría en su libertad frente a quien lo nombra y a quien contrata, lo que implica la absoluta autonomía de sus decisiones, contando además con el acceso irrestricto a los medios de comunicación masiva.

Es seleccionado por el Congreso. En efecto, este órgano lo designa y reemplaza con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes procediendo a elegir un candidato de una terna propuesta por la Comisión Bicameral Permanente, por un mandato de cinco años renovable por una sola vez, exigiendo como condiciones para su postulación ser de nacionalidad argentina o nativo por opción, mayor de 30 años edad y tratarse de una persona íntegra, de decir, que debe gozar de un amplio prestigio e ilustración en la esfera nacional.

Asimismo no se requiere que posea conocimientos de derecho, pero conforme el organigrama del órgano para el nombramiento de los dos adjuntos con los que debe contar quienes son nombrados por la Comisión Bicameral a propuesta del Defensor, sí deben ser abogados con reconocida versación en derecho público.

Por las características del cargo, el mismo es incompatible con toda actividad pública, comercial, profesional o política partidaria, pudiendo excepcionalmente realizar tareas de docencia.

Al no depender en su función del P.L., su actividad no se interrumpe en la época de recesos parlamentarios, en períodos de estado de emergencia o situaciones de transición o estado de sitio.

La ley que rige el funcionamiento del órgano plasma el mentado principio de independencia al garantizar al Defensor del Pueblo el ejercicio de sus funciones sin recibir instrucciones de ninguna autoridad, en mérito a su autonomía funcional, otorgándole además inmunidades y privilegios semejantes a la de los legisladores.

8. COMPETENCIA Y LEGITIMACIÓN

En lo concerniente al Poder Judicial, tenemos que su función específica converge con el funcionamiento de los Juzgados y Tribunales como servicio público. En países como Suecia y España, el Defensor del Pueblo se encuentra legitimado para intervenir en este contexto.

En nuestro país han existido reclamos ante el Defensor por la desidia y burocratización judicial. Y tan solo en algunos tribunales le respondieron, brindándole información acerca del estado de tramitación de las causas que le fueron requeridas.

Así, la Cámara Federal de Apelaciones de la Seguridad Social le dio legitimación para que pida la remisión a la A.N.Se.S. de un expediente por el que se tramitaba el reajuste de un haber jubilatorio.

El Ombudsman por medio de la Cámara Nacional Electoral invitó a instar a los Juzgados Federales con competencia electoral de los distintos distritos del país para que verificaran el cumplimiento de los porcentajes del cupo femenino en las listas de candidatos presentadas para su registro por los partidos políticos.

Pero la Corte Suprema Nacional no actuó de igual manera ante un reclamo del Defensor por el que pidió que se arbitraran los medios conducentes para el dictado de una sentencia. En este caso, la Corte resolvió que el Defensor del Pueblo carece de competencia para formular exhortaciones al tribunal sobre las causas en trámite; resolviendo desestimar la presentación.

La Corte manifestó que aunque en el art. 43 de la Constitución Nacional se reconocía legitimación para promover la acción de amparo a sujetos potencialmente distintos de los afectados en forma directa por el acto o la omisión, no se seguía de ello la aptitud para demandar sin que existiera cuestión susceptible de instar el ejercicio de la jurisdicción. Admitir la legitimación en un grado que la identificase con el "generalizado interés de todos los ciudadanos en el ejercicio de los poderes del gobierno... deformaría las atribuciones del Poder Judicial en sus relaciones con el Ejecutivo y con la Legislatura y lo expondría a la imputación de ejercer el gobierno por medio de medidas

cautelares". Este fallo (6) fue dictado por unanimidad y simultáneamente con otros dos relevantes "Defensor del Pueblo", y "Consumidores Libres" (7), todos del 7 de mayo de 1998, dando lugar a fuertes críticas de la doctrina.

Hay que tener en cuenta que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la República Argentina a partir del precedente "Frias Molina" (8) había sistemáticamente negado la legitimación activa para iniciar acciones judiciales, por entender que interfiere en contiendas judiciales concretas.

En efecto, en este caso "Frias Molina c. INPS. Caja Nacional de Previsión para el Personal del Estado y Servicios Públicos s/ reajuste por movilidad", el Defensor del Pueblo interpuso en forma directa, sin ser parte en el recurso extraordinario —en trámite por reclamo de actualización de haberes jubilatorios— un pedido de pronto despacho, exhortando a la Corte a que arbitrara los medios conducentes para el dictado de la sentencia. La Corte también se pronunció en contra de la legitimación procesal para estar en juicio del Defensor del Pueblo, considerando que éste carecía de competencia para formular exhortaciones sobre causas en trámite y que pretendía operar como un contralor administrativo del Poder Judicial.

Lo que no se tuvo en cuenta es que el Defensor del Pueblo lo hacía como legitimado constitucional para estar en juicio en defensa de los derechos humanos tutelados por el art. 86 de la Constitución Nacional.

Transcurrido un año y persistiendo la situación de mora judicial en que se hallaba la Corte Suprema en las causas, el Defensor hizo una nueva presentación haciéndose parte en la causa solicitando pronto despacho y haciendo extensiva la exhortación al resto de las presentaciones de igual tenor que se encontraban varadas en la sede del Alto Tribunal. La Corte volvió a rechazarla desconociendo la legitimación constitucional del Defensor, lo que determinó su presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington.

Ello fue recién mejorándose en la causa: "Camuzzi Gas del Sur S.A. s/ solicita intervención en autos 'Defensor del Pueblo de la Nación c. Telecom. Argentina Stet France Telecom. S.A. y otros'" del 15/8/2002, donde este criterio restrictivo pareció flexibilizarse al rechazar el recurso deducido por una empresa de servicios públicos, contra una medida cautelar por la cual el Tribunal de Segunda Instancia en lo Civil y Comercial Federal, resolvió la prórroga por única vez, sin recargo y por 20 días corridos, del plazo para abonar las facturas de distintos servicios públicos.

Pero su legitimación ante el más Alto Tribunal, fue admitida en forma amplia por un sector (hoy mayoría) de la Corte el 24 de mayo de 2005 en la causa "Defensor del Pueblo c. P.E. y ENER GAS" para interponer acción de amparo con relación a derechos de incidencia colectiva.

(6) "Prodelco", Fallos: 321:1252 (consid. 25, p. 1299).

(7) CSJN, Fallos: 321:1187 y Fallos: 321:1352.

(8) CSJN, 21/3/1995. Fallos 318:384.